

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 243.752 van 19 februari 2019

in de zaak A. 219.960/XII-8204

In zake:

1. de NV BESIX
2. de NV ONDERNEMINGEN JACQUES DELENS
samen vormend een tijdelijke handelsvennootschap
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaten Bob Martens en Annelies Verlinden
kantoor houdend te 1050 Brussel
Louizalaan 106
bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL
VERVOER TE BRUSSEL (MIVB)
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaten Véronique Vanden Acker en François Viseur
kantoor houdend te 1050 Brussel
Louizalaan 140
bij wie woonplaats wordt gekozen
eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Kris Wauters

Tussenkommende partij:

1. de NV AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE
2. de NV CIT BLATON
samen vormend een tijdelijke vennootschap
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Carlos De Wolf
kantoor houdend te 9680 Maarkedal
Etikhovestraat 6
bij wie woonplaats wordt gekozen
eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Charlotte De Wolf

I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 22 september 2016, strekt tot de nietigverklaring van “de beslissing van de Raad van Bestuur van [de MIVB] van 20 juli 2016 [...] tot gunning van de opdracht ‘Werken betreffende de bouw van een metrostelplaats’ aan THV CFE-Blaton, en derhalve niet aan [de nv Besix en de nv Ondernemingen Jacques Delens]”.

Voorts vorderen de nv Besix en de nv Ondernemingen Jacques Delens een schadevergoeding tot herstel ten belope van 7.969.910,13 euro.

II. Verloop van de rechtspleging

2. Bij arrest nr. 235.683 van 6 september 2016 is de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing verworpen.

De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

Auditeur Thomas Maes heeft een verslag opgesteld.

De verzoekende partijen en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 23 oktober 2018 en 27 november 2018.

De tussenkomende partij heeft bij brief van 20 november 2018 afstand van haar tussenkomst gedaan.

Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Matthias Stinissen, *loco* advocaten Annelies Verlinden en Bob Martens, die verschijnen voor de verzoekende partijen, advocaten Kris Wauters en François Viseur, die verschijnen voor de verwerende partij, en advocaat Carlos De Wolf, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

Auditeur Thomas Maes heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor de uitvoering van werken genaamd “Stelplaats Erasmus - Algemene aanneming voor de bouw van een ondergrondse metrostelplaats”. De plaatsingswijze is een onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking op grond van artikel 53, § 1, van de wet van 15 juni 2006 ‘overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten’ (hierna: wet overheidsopdrachten 2006).

De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen op 21 maart 2014 en in het supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie op 26 maart 2014.

De opdracht valt onder de overheidsopdrachtenregelgeving inzake de speciale sectoren. Ze is onderworpen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 ‘plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren’ (hierna: koninklijk besluit plaatsing speciale sectoren).

In de aankondiging wordt de opdracht als volgt omschreven:

“1. Huidige opdracht betreft de bouw van een nieuwe metrostelplaats Erasmus, een nieuw industrieel, voornamelijk ondergronds gebouw bestemd voor de exploitatie van een metrostelplaats voor de voertuigen van de MIVB. Ter indicatie bevat de huidige opdracht vooral:

- de vernieling (en na de werken, de terug-in-staat-stelling) van de Simonet-laan tussen de Lennikse Weg en de spoorwegbrug;
- studie en realisatie van een ondergrondse stelplaats die volgende elementen omvat:
 - een zone voor de stalling van 23 voertuigen;
 - een onderhoudszone (atelier) voor 7 voertuigen;
 - 2 transfertzones (2 x 1 voertuig);
 - een was-zone (2 voertuigen);
 - een by-pass spoor;
- een technisch blok dat volgende elementen huisvest: burelen, een informatica-laboratorium, technische lokalen, een (permanent) Operating Control Center - lokaal, een magazijn met losse stukken, 1 of 2 elektrische onderstations;
- een administratief blok dat volgende elementen huisvest: een zone voor de stalling en overzetting van draaistellen, sociale lokalen (refter, ontspanning), een vormingscentrum;
- studie en realisatie van een testspoor van ongeveer 1200 meter net naast de stelplaats, dat een assemblagespoor omvat (ongeveer 210 meter) alsook een spoor voor de werftreinen (toevoer van een deel van de perronwanden in de stations)”.

De opdracht kadert binnen het zogenaamde “Pulsar”-programma van de MIVB om de Brusselse metro te automatiseren en maakt deel uit van dit ruimer geheel aan moderniseringswerken.

3.2. Vijf kandidaten dienen een aanvraag tot deelneming in:

- de tijdelijke handelsvennootschap Besix Entreprises-Jacques Delens (hierna: Besix-EJD);
- de tijdelijke handelsvennootschap CEI De Meyer-Valens-Enterprises Louis De Waele;
- de tijdelijke handelsvennootschap CFE-Blaton (hierna: CFE-Blaton);
- de tijdelijke handelsvennootschap Denys-DEMOCO;
- de tijdelijke handelsvennootschap Franki Construct-Jan De Nul (hierna: Franki Construct-Jan De Nul).

Met een beslissing van 26 juni 2014 worden deze vijf kandidaten geselecteerd. Zij ontvangen het bestek en worden uitgenodigd om een eerste offerte in te dienen.

3.3. Het bestek bepaalt dat de opdracht in drie fasen zal verlopen:

“Fase 1 van deze opdracht heeft betrekking op de realisatie van het deel burgerlijke bouwkunde van de stelplaats, de functie ‘stalling’ van de stelplaats, alsook de gedeeltelijke uitrusting van de onderhoudswerkplaats.

Inbegrepen zijn de technische uitrustingen en installaties die niet voorkomen in fase 2 ‘uitrusting van de werkplaats’ noch in fase 3 ‘testspoor’. In dat opzicht omvat deze fase hoofdzakelijk:

- De afbraak van de Simonetlaan tussen de Lennikse Baan en de spoorwegbrug;
- De studie en de realisatie van een voornamelijk ondergrondse stelplaats omvattende:
 - een stallingszone (‘RE’);
 - een technisch blok waarin het volgende zich bevindt: burelen, een computerlabo, technische lokalen, een local Operating Control Center (OCC), een magazijn met losse onderdelen, twee elektrische onderstations;
 - een administratief blok (bovengronds) (‘BA’) waarin het volgende zich bevindt: een zone voor opslag en overslag van draaistellen, sociale lokalen (refter, ontspanning), een opleidingscentrum;
 - een onderhoudszone (werkplaats of onderhoudswerkplaats - ‘AM’), omvattende alle volgende technische uitrustingen en installaties:
 - hefstand V53;
 - lift 10 ton;
 - hoge perrons V54 (kuil);
 - 1 rolbrug verbonden met deze kuil;
 - 1 vaste loopbrug verbonden met deze kuil;
 - 1 hefplatform verbonden met deze kuil;
 - leggen van de vereiste sporen (sporen V54 en V53), alsook van de sporen en spoortoestellen voor de aansluiting op de transferpositie;
 - laagspanning;
 - HVAC;
 - stootblok op spoor V54
 - perslucht.

Fase 2 van deze opdracht heeft betrekking op de levering en de installatie van de andere onderhoudsuitrustingen, met name:

- het resterende deel van de hoge perrons;
- 1 rolbrug;
- 1 stootblok;
- het resterende deel van de loopbruggen op het dak;
- de wasstand;
- de hogedrukreiniger;
- de centrale stofzuigereenheid;
- de rolbrug van het administratief gebouw;
- het resterende deel van de te leggen sporen
- het resterende deel van de hefplatformen.

Fase 3 van deze opdracht omvat voornamelijk de studie en de realisatie van een testspoor (bovengronds) van ongeveer 1200 m grenzend aan de stelplaats en beschikkend over een assemblagespoor (ongeveer 210 m) en een werktreinspoor (vervoer van een deel van de perrongevels in de stations).”

Het bestek voorziet in het volgende verloop van de onderhandelingsprocedure: eerst dienen de geselecteerde inschrijvers een eerste offerte (“First Offer” of “FO”) in, waarna:

“Aan het einde van de analyse van de First Offer en van eventuele onderhandelingen en/of van verduidelijkingen zal de aanbestedende overheid een voorlopige rangschikking van de offertes opstellen. Hij zal maximum 3 inschrijvers weerhouden die desgevallend verzocht zullen worden te onderhandelen en vervolgens een BAFO [‘Best And Final Offer’] in te dienen.

Aan het einde van de analyse van de BAFO zal de aanbestedende overheid een eindrangschikking van de offertes opstellen op basis van een volledige toepassing van de gunningscriteria.”

Over de inhoud van en de verhouding tussen de eerste offertes en de BAFO’s wordt in het bestek bepaald:

“Ongeacht de bepalingen van het KB van 16 juli 2012 moet de offerte, om geldig te zijn, alle documenten omvatten die vermeld staan in bijlage K. De inschrijver zal erop toezien dat het maximumaantal pagina’s, vermeld in deze bijlage, niet overschreden wordt.

De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat het offertedossier, in te dienen voor de First Offer, verschillend is van het offertedossier dat later ingediend moet worden voor de BAFO. Naar aanleiding van de First Offer, zal de aanbieder uitsluitend de documenten

indienen die aangeduid zijn in de kolom ‘First Offer’ (Bijlage K). Naar aanleiding van de BAFO-offerte, zal de aanbieder de reeds in First Offer ingediende documenten opnieuw indienen, alsook de documenten aangeduid in de kolom ‘BAFO’ (Bijlage K)”.

Over het verloop van de onderhandelingen wordt in het bestek bepaald:

“In toepassing van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2012 betreffende de gunning van de overheidsopdrachten in de speciale sectoren zal de opdracht gegund worden d.m.v. een onderhandelingsprocedure met publicatie, overeenkomstig de principes vermeld in bepaling 2.10.

Deze procedure zal voor de inschrijvers zo economisch en doeltreffend mogelijk verlopen. Men zal er hierbij over waken dat de gelijkheid tussen de inschrijvers strikt nageleefd wordt.

Tijdens de onderhandelingen kunnen inschrijvers gezamenlijk of afzonderlijk, maar in gelijkaardige omstandigheden, ontvangen worden door een delegatie van de MIVB en van de vertegenwoordigers en raadgevers ervan.

Tijdens deze eventuele vergaderingen:

- krijgt de inschrijver de gelegenheid om de sterke punten van zijn offerte te benadrukken;
- zal de inschrijver eventueel verzocht worden om de technische, administratieve en financiële aspecten van zijn offerte verder toe te lichten.

Tijdens deze vergaderingen zal de aanbestedende overheid het accent leggen op de voornaamste elementen die in de offerte eventueel nog kunnen verbeterd worden.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om op elk moment te opteren om de onderhandelingen verder te zetten met alle inschrijvers of met bepaalde inschrijvers in functie van de voorlopige resultaten. De aanbestedende overheid kan echter, op ieder ogenblik, de onderhandelingen met de andere inschrijvers hervatten.

De communicatie met de inschrijvers kan tijdens de onderhandelingen zowel schriftelijk, door verzending van een brief per post, per fax of via elektronische weg verlopen.

Deze benadering moet er in essentie voor zorgen dat noch de inschrijvers, noch de aanbestedende overheid tot grote en nutteloze kosten zouden gedwongen worden.”

Voorts zijn in artikel 2.10 van het bestek de volgende vier gunningscriteria, elk met meerdere sub(sub)criteria, bepaald:

- “1. Totale prijs van de offerte (450 punten); [...]
- 2. Voorstel uitvoeringsplanning & werfinstallatieplan voor fase 1 - naleving van en inzicht in de fasering van fase 1 (100 punten);
 - 1. Een werfinstallatieplan (30 punten);
 - 2. Een uitvoeringsplanning (40 punten);
 - 3. Fasering van de uitvoering en van de tussenmijlpalen (30 punten);
- 3. Technische dossiers (400 punten) [...];
- 4. Duidelijkheid van de offerte (50 punten) [...].”

Het tweede gunningscriterium “Voorstel uitvoeringsplanning & werfinstallatieplan voor fase 1 – naleving van en inzicht in de fasering van fase 1”, wordt in het bestek als volgt omschreven:

“2.10.2. Voorstel uitvoeringsplanning & werfinstallatieplan voor fase 1 – naleving van en inzicht in de fasering van fase 1 (100 punten)

Er wordt aan de inschrijvers gevraagd een gedetailleerd voorstel over te maken voor de hieronder beschreven aspecten (fase 1), in het Algemeen Programma van de Werken (zie bepaling 2.2 en Bijlage L). Realistische voorstellen zullen, na eventuele discussie en uitleg tijdens de onderhandelingen, beloond worden.

(1) Een werfinstallatieplan (30 punten): Een werfinstallatieplan dat volledig conform is met dit bestek en dat de mobilisatietermijn preciseert, wordt beloond met 30 punten; Voorstellen die niet conform zijn met dit bestek of irrealistisch zijn, zullen bestraft worden, desgevallend tot een nulscore (0 punten);

(2) Een uitvoeringsplanning (40 punten) : Een kwalitatief voorstel van uitvoeringsplanning dat de finale uitvoeringstermijn voorgesteld door de aanbestedende overheid herleidt, zal beloond worden, desgevallend tot de maximale score voor dit subcriterium (40 punten);

(3) Fasering van de uitvoering en van de tussenmijlpalen (30 punten): Een kwalitatief voorstel dat de termijnen voor de tussenmijlpalen voorgesteld door de aanbestedende overheid herleidt, zal beloond worden, desgevallend tot de maximale score voor dit subcriterium (40 punten).”

Voorts bepaalt het bestek het volgende over de planning en de fasering van de opdracht:

“Elke fase van deze opdracht heeft zijn eigen uitvoeringstermijnen, zijn eigen tussenmijlpalen, zijn eigen voorlopige en definitieve oplevering en zijn eigen waarborgtermijn.

Voor de details van de planning en de mijlpalen van huidige opdracht, wordt verwezen naar Bundel III.2, § 4 van de technische bepalingen”.

In de bedoelde technische besteksbepalingen, volume III, Bundel 2, hoofdstuk 4, wordt de planning van het Erasmus project verduidelijkt, met opsomming van de kritieke mijlpalen (1^{ste} doelstelling Pulsar en 2^{de} doelstelling Pulsar), de opgelegde mijlpalen (o.m. voorlopige oplevering en definitieve oplevering fase I) en de tussenmijlpalen waarvan sommigen “te rechtvaardigen en te verduidelijken door de inschrijver” of “in te vullen door de inschrijver” of al worden ingevuld, zoals de in deze zaak kwestieuze mijlpaal “T1+18m”, die inhoudt dat 18 maanden na de aanvang van de werken “de 5 eerste opstelposities in de stelplaats, verbindingssporen naar Erasmus station inbegrepen” ter beschikking kunnen worden gesteld.

3.4. De vijf geselecteerde inschrijvers dienen allen een eerste offerte in op 2 maart 2015. Er wordt een rangschikking van deze eerste offertes opgesteld en de drie best gerangschikte inschrijvers worden op 20 mei 2015 toegelaten tot verdere onderhandelingen. Het zijn de volgende inschrijvers:

- CFE-Blaton;
- Franki Construct-Jan De Nul;
- Besix-EJD (de verzoekende partijen).

3.5. In de loop van mei en juni 2015 worden een aantal vergaderingen met deze drie inschrijvers georganiseerd.

Op 15 juni 2015 stuurt de verwerende partij een bericht aan de drie inschrijvers:

“Om uw planning en de organisatie van uw site, zo nodig, te kunnen aanpassen, vindt u hieronder belangrijke informatie.

Bij de voorbereiding van de planning is het belangrijk dat de sporen van het achterstation Erasmus zo laat mogelijk betrokken worden. Het wegnemen ervan veroorzaakt namelijk een onaanvaardbare vermindering van de bedrijfsomstandigheden van het eindstation Erasmus. Gelieve dus met de hieronder beschreven perioden rekening te houden.

1. Behoudsperiode van de sporen in het achterstation: zo lang mogelijk. Uw interventie is mogelijk in deze zone, maar u mag het omgrenzingsprofiel niet beïnvloeden. Geen enkele vermindering van de exploitatie is toegestaan.
2. Periode zonder twee ineengeschoven spoorverbindingen, maar u mag niet dichterbij dan 50 meter (= veiligheidsafstand) van het einde van het perron komen: zo kort mogelijke periode. In deze periode worden de twee ineengeschoven spoorverbindingen gedemonteerd en wordt de dalende helling in de stelplaats gebouwd. Aanzienlijke vermindering van de exploitatie.
3. Werkperiode in de nabijheid van de perrons (sporenaanleg) (tussen het einde van het perron en het einde van de veiligheidsafstand van 50m): zeer kort, weekendwerk, één perron per keer. Zeer grote vermindering van de exploitatie (onbruikbaar perron)”.

Met een bericht van 19 juni 2015 worden de drie inschrijvers uitgenodigd om een BAFO in te dienen. Bij deze uitnodiging is een terechtwijzend bericht “AR02-TWB02” gevoegd, met een nieuwe bijlage K die de documenten opsomt die naar aanleiding van de BAFO bij de offertes moeten worden gevoegd.

Het geciteerde bericht van 15 juni 2015 werd opgenomen in dat terechtwijzend bericht AR-TWB 02, en werd nog op 30 juli 2015 bevestigd in antwoord op een vraag van de verzoekende partijen.

3.6. Op 18 september 2015 dienen de drie overblijvende inschrijvers hun BAFO in.

3.7. Met een aangetekend schrijven van 4 december 2015 wordt iedere inschrijver individueel uitgenodigd om zijn BAFO voor te stellen op 14, 15 dan wel 16 december 2015.

3.8. Op 18 december 2015 contacteert de verwerende partij de drie inschrijvers met opmerkingen en vragen in verband met de analyse van de BAFO's.

In de voormelde brief van 18 december 2015 deelt de verwerende partij onder meer het volgende mee:

“ID 2180 [...] Création d'un terminus en avant-gare de la station Erasme AVANT d'entamer les travaux d'arrière gare :

La STIB va créer le terminus en avant-gare de la station Erasme en ajoutant une communication et des butoirs provisoires (qui seront réutilisés pour la voie d'essai). Cela veut dire que le choix du quai de départ / d'arrivée sera fait avant d'arriver dans la station et non plus après comme actuellement. La fin de ces travaux est prévue en décembre 2017. A partir de ce moment, le travail en arrière-gare sera possible sans plus aucune contrainte d'exploitation (pas de rames, pas de 900V,...). Le risque d'interférence de l'exploitation avec le chantier sera donc quasiment nul. Nous partons du principe que votre planning pourra, le cas échéant, être adapté en fonction de cette nouvelle donnée.

[...]

ID 2208 [...] Veuillez noter que le jalon demandant un accès au dépôt pour les 5 premiers trains en T0+18 mois est supprimé.”

[vertaling: Creatie van een eindstation vóór de halte Erasmus vooraleer de werken aan te vatten in het achterstation:

De MIVB zal een eindstation creëren vóór de halte Erasmus d.m.v. de installatie van een wissel en voorlopige stootblokken (die hergebruikt zullen worden voor het testspoor). Dit betekent dat de keuze van het vertrek- of aankomstperron zal gemaakt worden alvorens de halte binnen te rijden en niet meer erna zoals momenteel voorzien. Het einde van deze werken is voorzien voor eind december 2017. Vanaf dat moment kunnen de werken in het achterstation uitgevoerd worden zonder enige belemmering ten gevolge van de exploitatie (geen metrostellen, geen 900V, ...). Het risico van interferentie tussen de exploitatie van de metrolijn en de werf zal dus zo goed als nul zijn. Wij vertrekken van het principe dat uw planning, in voorkomend geval, kan worden aangepast in functie van dit nieuwe gegeven.

[...]

ID 22208 [...] Gelieve te noteren dat de mijlpaal die een toegang tot de stelplaats vraagt voor de eerste 5 metrostellen op T0 [lees: T1] +18 maanden vervalt.”

3.9. Vervolgens worden de BAFO's onderzocht.

Op 20 juli 2016 neemt de verwerende partij de thans bestreden gunningsbeslissing, die het gunningsverslag meteen in zich draagt.

In de gunningsbeslissing wordt eerst de beoordeling van de eerste offertes van de oorspronkelijke vijf inschrijvers weergegeven, vervolgens wordt overgegaan tot de beoordeling van de BAFO's van de drie overblijvende inschrijvers. Na toetsing van de BAFO's aan de gunningscriteria komt de verwerende partij tot de volgende eindrangschikking van de BAFO's:

“K.- Rangschikking na BAFO

De rangschikking na evaluatie van de BAFO en de aanvullingen van informatie geleverd door de inschrijvers in de loop van de procedure, is de volgende:

Inschrijver	BESIX – EJD	CFE – BLATON	FRANKI – JAN DE NUL
Totaalprijs van de offerte op 450 punten	440	450	441
<i>Investeringskosten op 400 punten</i>	391	400	400
<i>Kost van de energiebalans op 50 punten</i>	49	50	41
Planning op 100 punten	54	81	60
<i>Werfinstallatie op 30 punten</i>	18	18	18
<i>Uitvoering op 40 punten</i>	24	36	24
<i>Fasering op 30 punten</i>	12	27	18
Technische dossiers op 400 punten	271	253	248
<i>Ruwbouw op 70 punten</i>	56	53	52
<i>Afwerkingen op 20 punten</i>	16	15	12
<i>Speciale technieken metro op 100 punten</i>	89	67	60
<i>Speciale technieken gebouwen op 110 punten</i>	55	65	49
<i>Methodologie op 100 punten</i>	55	53	75
Duidelijkheid van de offerte op 50 punten	45	39	39
<i>Structuur en presentatie op 25 punten</i>	24	20	19
<i>Volledigheid op 25 punten</i>	21	19	20
Totaal op 100 punten	810	823	788

”

De verwerende partij beslist vervolgens om de opdracht te gunnen aan de CFE-Blaton voor een bedrag van 77.980.404,86 euro, btw niet inbegrepen.

Dit is de bestreden gunningsbeslissing.

De huidige verzoekende partijen zijn de als tweede gerangschikte inschrijver.

IV. Ontvankelijkheid van het beroep

4. De verwerende partij werpt in de memorie van antwoord op dat het beroep niet ontvankelijk is in de mate dat het is gericht tegen de impliciete weigering om de opdracht aan de verzoekende partijen te gunnen. De verzoekende partijen tonen volgens haar niet aan dat het gegronnd bevinden van één van hun middelen de verwerende partij zou verplichten om de opdracht aan hen te gunnen.

5. In de memorie van wederantwoord doen de verzoekende partijen gelden dat zij wel degelijk over het vereiste belang beschikken om de nietigverklaring te vorderen van de impliciete weigeringsbeslissing. Zij betogen dat zij in hun vierde en vijfde middel aantonen dat de beoordeling van de offertes foutief is en dat de puntentoekenning evenmin correct is.

Beoordeling

6. Het beroep tegen de impliciete beslissing om de opdracht niet aan de verzoekende partijen te gunnen is niet *a priori* onontvankelijk.

Het onderzoek naar de ontvankelijkheid van het beroep in de mate dat het gericht is tegen de impliciete weigeringsbeslissing om de opdracht aan de verzoekende partijen te gunnen, hangt te dezen samen met het onderzoek en het gegronnd bevinden van de middelen.

V. Vertrouwelijkheid van de stukken

7. De verzoekende partijen voegen hun stukken 18 – uittreksel uit hun BAFO – en 19 – vergelijking van hun planning in de First Offer en de BAFO – bij het verzoekschrift als vertrouwelijke stukken.

De verzoekende partijen vragen daarnaast om inzage in de uitvoeringsplanning van de gekozen inschrijver, “inzonderheid wat betreft de naleving van mijlpaal T1+18, zoals ingediend bij de BAFO op 18 september 2015”. Zij beschouwen dit stuk als “van cruciaal belang voor de beoordeling van het vierde middel”:

“Uit deze planning zal immers blijken dat CFE-Blaton op het ogenblik van de BAFO niet voldeed aan mijlpaal T1+18 en deze mijlpaal in strijd met de bepalingen van het bestek werd overschreden.

Vanuit die optiek is het dan ook noodzakelijk om minstens dit onderdeel van de BAFO van CFE-Blaton als niet-vertrouwelijk aan te merken en de verzoekende partijen hierin inzage te verschaffen.”

De verzoekende partijen vragen om “bij tussenarrest, dan wel op verzoek van de Auditeur” de vertrouwelijkheid van het betrokken stuk op te heffen en hen de mogelijkheid te geven het vierde middel en mogelijk ook de andere middelen aan te vullen of uit te breiden.

8. De verwerende partij voegt een reeks stukken bij het administratief dossier die zij als vertrouwelijk aanmerkt. Het gaat om de eerste offertes en de BAFO’s van de drie inschrijvers, documenten van de inschrijvers inzake de laagspanningsinstallaties en een nota over het financieel nazicht van de BAFO’s.

Wat de vraag van de verzoekende partijen om inzage in de uitvoeringsplanning van de gekozen inschrijver betreft, verklaart de verwerende partij in haar memorie van antwoord dat zij deze inzage weigert. De wijze waarop een onderneming haar planning organiseert is één van de elementen die haar

onderscheiden van mogelijke concurrenten. Dergelijke planning wordt volgens de verwerende partij opgesteld op grond van jarenlange ervaring in vergelijkbare complexe opdrachten, die een onderneming niet zomaar te grabbel gooit. Het is niet aan de aanbestedende overheid om die informatie mee te delen. De verwerende partij vreest dat deze informatie de verzoekende partijen voor de toekomst een marktverstoring voordeel biedt. Doordat de Raad van State volledige inzage krijgt, worden de rechten van verdediging gewaarborgd, aldus de verwerende partij.

9. Bij hun memorie van wederantwoord voegen de verzoekende partijen nog de als vertrouwelijk aangemerkte stukken 29, 30, 31 en 32. Het betreft diverse uittreksels uit hun First Offer en hun BAFO.

De verzoekende partijen benadrukken dat de uitvoeringsplanning van de gekozen inschrijver cruciaal is voor hun vierde middel en de daarin aangevoerde wettigheidskritiek dat de planning van de gekozen inschrijver CFE-Blaton bij de BAFO van 18 september 2015 de mijlpaal T1+18 niet naleeft. Zij hernemen hun vraag om inzage in dit onderdeel van het vertrouwelijk stuk E van het administratief dossier.

In replek op het betoog in de memorie van antwoord doen de verzoekende partijen gelden dat de planning verschilt van opdracht tot opdracht en dat de planning van CFE-Blaton niet dermate uitzonderlijk is dat zij vertrouwelijk moet blijven. De verwerende partij toont niet aan welk concurrentieel voordeel aan de verzoekende partijen zou worden verschaft wanneer zij inzage zouden krijgen in de planning van CFE-Blaton enkel met het oog te kunnen nagaan of mijlpaal T1+18 werd nageleefd.

Beoordeling

10. De behandeling van vertrouwelijke gegevens door de Raad van State in het kader van betwistingen inzake de gunning van overheidsopdrachten

wordt op de eerste plaats geregeld door artikel 26 van de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies’ (hierna: wet van 17 juni 2013).

De stukken waarvan de vertrouwelijke behandeling wordt gevraagd zijn door de partijen afzonderlijk neergelegd, de vertrouwelijkheid ervan wordt telkens uitdrukkelijk aangegeven en vermeld in de inventaris. De motieven voor de gevraagde vertrouwelijke behandeling worden weergegeven in het verzoekschrift en de memories.

Bovendien wordt het vertrouwelijk karakter van de betrokken stukken door geen van de partijen betwist, behoudens wat betreft het vertrouwelijk stuk E van het administratief dossier.

Voorts valt op te merken dat de Raad van State van deze informatie kennis kan nemen en ze in zijn onderzoek en beoordeling van de zaak mag betrekken.

De Raad van State gaat dan ook in op de vragen tot vertrouwelijke behandeling.

11. De verzoekende partijen vragen wel kennis te mogen nemen van het vertrouwelijk stuk E van het administratief dossier – dit is de BAFO van de gekozen inschrijver – in het bijzonder wat de in deze BAFO opgenomen uitvoeringsplanning betreft. Zij vragen om daarin inzage te krijgen omdat deze informatie volgens hen cruciaal is voor hun vierde middel. De verwerende partij betwist dat inzage moet worden toegestaan.

Overeenkomstig artikel 26 van de wet van 17 juni 2013 komt het aan de Raad van State toe om het aangevoerde vertrouwelijk karakter van het betrokken stuk van het administratief dossier te beoordelen en daarbij de

vereisten van een effectieve rechtsbescherming en een eerlijk proces af te wegen tegen die van de bescherming van het zakengeheim. Het vertrouwelijk karakter van het betrokken stuk belet bovendien niet dat de Raad van State daarop acht mag slaan en deze gegevens bij zijn beoordeling mag betrekken.

Wat de genoemde afweging betreft, dient te dezen op de eerste plaats in aanmerking te worden genomen dat de voorliggende opdracht, blijkens de opdrachtdocumenten, bijzonder complexe werkzaamheden betreft die moeten worden uitgevoerd in moeilijke omstandigheden. Het gaat met andere woorden niet om een alledaagse opdracht in een normaal concurrentiële omgeving, maar om werken met een aanzienlijke moeilijkheidsgraad waarvoor slechts enkele zeer gespecialiseerde ondernemingen in aanmerking komen om ze uit te voeren.

Op de tweede plaats moet in overweging worden genomen dat de betrokken uitvoeringsplanning uit haar aard uitermate gedetailleerde gegevens bevat over de door de gekozen inschrijver voorgestelde technieken en uitvoeringsmethoden, diens specifieke knowhow, zijn uitrusting en materieel en daarnaast een reeks andere gevoelige gegevens die alle moeten worden beschouwd als onder het zakengeheim van de betrokken inschrijver vallend. Er blijkt dan ook niet dat de uitvoeringsplanning van de gekozen inschrijver ten onrechte als vertrouwelijk zou zijn aangemerkt door de verwerende partij en om die reden alleen reeds ter inzage van de verzoekende partijen zou moeten worden gegeven.

De verwerende partij mag voorts worden bijgevalen waar zij doet gelden dat de wijze waarop een inschrijver zijn uitvoeringsplanning opstelt voor de betrokken gecompliceerde werken één van de elementen vormt die hem bij uitstek onderscheiden in de concurrentiestrijd tussen de inschrijvers. Een dergelijke planning wordt immers opgesteld op grond van jarenlange ervaring in vergelijkbare complexe opdrachten. De vrees van de verwerende partij dat deze informatie de verzoekende partijen een marktverstoring voordeel voor de toekomst zou geven lijkt niet ongegrond.

Waar de verzoekende partijen hun verzoek tot het lichten van de vertrouwelijkheid toespitsen op de wettigheidskritiek die zij doen gelden in het vierde middel inzake de overeenstemming van de BAFO-uitvoeringsplanning van de gekozen inschrijver met de mijlpaal T1+18, dienen zij te worden gewezen op het feit dat het vertrouwelijk karakter van het betrokken stuk de Raad van State, gelet op de vereisten van een eerlijk proces, niet belet om de juistheid van deze grief na te gaan en te onderzoeken of deze al dan niet grond vindt in het betrokken stuk.

Er wordt aldus niet ingegaan op de vraag tot opheffing van de vertrouwelijkheid van het betrokken stuk.

VI. Onderzoek van de middelen

A. Eerste middel

Uiteenzetting van het middel

12. De verzoekende partijen voeren de schending aan van artikel 5 *juncto* artikel 55 van de wet overheidsopdrachten 2006, van artikel 106 van het koninklijk besluit plaatsing speciale sectoren, van het beginsel *patere legem quam ipse fecisti*, van artikel 10 en 11 van de Grondwet alsook van het algemeen beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Zij achten deze bepalingen en beginselen geschonden:

“Doordat verwerende partij het verloop van de gunningsprocedure, zoals duidelijk beschreven in het bestek, na de BAFO-fase heeft gewijzigd en vervolgens aanvaardde dat inschrijver CFE-Blaton een offerte na-BAFO heeft ingediend;

En doordat de evaluatie van de in het bestek voorgeschreven gunnings-criteria om de economisch meest voordelige offerte te bepalen bijgevolg

niet geschiedde op basis van de BAFO van CFE-Blaton, maar wel op basis van de offerte na-BAFO van CFE-Blaton;

Terwijl door verwerende partij het verloop van de gunningsprocedure duidelijk vooraf in het bestek is voorgeschreven waarbij werd bepaald dat de beoordeling van de gunningscriteria zal geschieden aan de hand van de BAFO van de inschrijvers, en een aanbestedende overheid, zoals verwerende partij, in overeenstemming met het *patere legem quam ipse fecisti*-beginsel, gebonden is door haar eigen in het bestek voorgeschreven regels;

En terwijl in overeenstemming met het *patere legem quam ipse fecisti*-beginsel en het gelijkheidsbeginsel de beoordeling van de gunningscriteria moet geschieden in overeenstemming met de in het bestek aangekondigde procedure;

Zodat vaststaat dat de aangehaalde bepalingen en rechtsbeginselen zijn geschonden.”

In hun toelichting bij het middel wijzen de verzoekende partijen erop dat het bestek bepaalt dat de inschrijvers tweemaal de mogelijkheid krijgen om een offerte in te dienen, een First Offer en een BAFO. Na de BAFO-fase kunnen de inschrijvers niet nog een offerte indienen of hun BAFO wijzigen. Op 2 maart 2015 werden de First Offers ingediend en op 18 september 2015 de BAFO's. Op 18 december 2015 deelde de verwerende partij belangrijke nieuwe informatie mee aan de inschrijvers die een aanzienlijke invloed had op de door de verzoekende partijen ingediende planning. Op 20 januari 2016 gaven de verzoekende partijen aan dat hun planning kon worden gewijzigd, zonder daadwerkelijk een aangepaste planning te bezorgen. De procedure bepaald in het bestek liet dit immers niet toe. CFE-Blaton heeft in weerwil van het bestek wel degelijk bijkomende informatie aan de verwerende partij bezorgd en een aangepaste planning ingediend. Aldus heeft CFE-Blaton op 20 januari 2016 in strijd met het bestek een offerte na-BAFO ingediend waarin zowel een gewijzigde planning is opgenomen als een aanzienlijke vermindering van de prijs met 361.700 euro. Ook werd door deze inschrijver een “lettre d’engagement” bezorgd inzake het gebruik van aan de werfsite palende terreinen.

De verwerende partij heeft in strijd met het bestek rekening gehouden met deze offerte na-BAFO van 20 januari 2016. Anders dan wordt gesteld in de gunningsbeslissing gaat het niet om een antwoord op vragen van de verwerende partij maar wel degelijk om een volledig nieuwe offerte na-BAFO met fundamentele herziening van planning en prijs, twee gunningscriteria. De verwerende partij erkent in de gunningsbeslissing dat zij de gunningscriteria heeft getoetst op grond van de offerte na-BAFO van CFE-Blaton. Dit erkende zij ook in haar nota met opmerkingen in de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid. De verwerende partij heeft aldus onvergelykbare offertes met elkaar vergeleken: enerzijds, de BAFO van de verzoekende partijen van 18 september 2015 waarin geen rekening is gehouden met de aanvullende informatie van 18 december 2015 en, anderzijds, de offerte na-BAFO van CFE-Blaton van 20 januari 2016 waarin wel met deze informatie rekening werd gehouden.

De flexibiliteit van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking is niet onbeperkt, aldus de verzoekende partijen. De verwerende partij heeft gehandeld in strijd met de door haarzelf vastgestelde bepalingen inzake het verloop van de onderhandelingsprocedure door de offerte na-BAFO van CFE-Blaton te aanvaarden terwijl het bestek niet in deze mogelijkheid voorzag.

13. In de memorie van wederantwoord betogen de verzoekende partijen nog dat de verwerende partij zelf – impliciet – had bevestigd dat er geen aangepaste planning kon worden ingediend. Op 7 januari 2016 immers bezorgde de verwerende partij opnieuw enkele vragen aan de inschrijvers, waarbij zij uitdrukkelijk verduidelijkte dat kolom G ‘bij te voegen documenten’ niet moest worden ingevuld door de inschrijvers. De verzoekende partijen mochten aannemen dat dit niet enkel betrekking had op de vragenlijst van 7 januari 2016 maar ook op de vragen van 18 december 2015. De verzoekende partijen hebben hieromtrent zelfs verduidelijking gevraagd op 11 januari 2016, waarop geen antwoord is gekomen van de verwerende partij. Aldus mochten de verzoekende partijen aannemen dat geen bijkomende documenten meer mochten worden ingediend, dan wel dat de BAFO niet meer mocht worden gewijzigd.

De verzoekende partijen wijzen erop dat CFE-Blaton in de offerte na-BAFO de in haar BAFO van 18 september 2015 voorgestelde technische oplossing en de verschillende mijlpalen die in het kader van de planning moesten worden nageleefd, heeft gewijzigd. De planning in de BAFO verschilt immers ontegensprekelijk van deze die met het antwoord van 20 januari 2016 aan de verwerende partij werd bezorgd. De verwerende partij kan dan ook niet beweren in de memorie van antwoord dat CFE-Blaton geen offerte na-BAFO heeft ingediend omdat het antwoord slechts een beperkt aantal elementen van de BAFO zou betreffen. Een offerte na-BAFO kan immers wel degelijk betrekking hebben op bepaalde elementen van de opdracht. Dat CFE-Blaton enkel haar planning zou hebben gewijzigd, doet dan ook geen afbreuk aan de vaststelling dat zij fundamentele wijzigingen aan haar BAFO heeft aangebracht die als een offerte na-BAFO mogen worden beschouwd.

De verwerende partij heeft volgens het gunningsverslag wel degelijk rekening gehouden met het nieuw gunstiger prijsvoorstel van CFE-Blaton in haar antwoord van 20 januari 2016.

In tegenstelling tot wat de verwerende partij in haar memorie van antwoord beweert, staat niet vast dat CFE-Blaton reeds in haar BAFO bewees dat zij over de nodige gronden voor werfinrichting zou kunnen beschikken. De verwerende partij beoordeelde de BAFO van CFE-Blaton kennelijk op grond van eigen informatie over de dochteronderneming nv Erasmus Gardens die niet in de BAFO zelf werd vermeld. Indien CFE-Blaton dit bewijs al zou hebben geleverd, zou er geen enkele reden zijn voor haar om op 20 januari 2016 nog een engagementsverklaring te bezorgen, aldus de verzoekende partijen. Ook op dit punt verschilt de BAFO van CFE-Blaton van de offerte na-BAFO die op 20 januari 2016 werd ingediend.

De bewering van de verwerende partij dat zij geen rekening heeft gehouden met de antwoorden van 20 januari 2016 en enkel de BAFO van CFE-Blaton heeft beoordeeld gaat in tegen de vaststellingen in het gunnings-

verslag. Dit heeft zij ook toegegeven in haar nota met opmerkingen in de procedure tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

De verzoekende partijen verwerpen tevens de verantwoording in de memorie van antwoord gesteund op het flexibel karakter van de onderhandelingsprocedure en wijzen erop dat ook in de onderhandelingsprocedure de flexibiliteit wordt begrensd door het gelijkheidsbeginsel en de regels die de aanbestedende overheid in haar bestek heeft bepaald. Het bestek is duidelijk: na de First Offer zal de verwerende partij onderhandelen met de drie inschrijvers, die vervolgens worden uitgenodigd om een BAFO in te dienen. Na het indienen van de BAFO zal een eindrangschikking worden opgesteld. De verwerende partij heeft zelf bepaald dat de onderhandelingen zullen plaatsvinden tussen de First Offer en de BAFO's. Onderhandelingen na de BAFO's zijn niet toegelaten door het bestek. De onderhandelingen zijn aldus beëindigd bij het indienen van de BAFO's op 18 september 2015 en de verwerende partij mocht niet meer onderhandelen. Het flexibel karakter van de onderhandelingsprocedure laat niet toe dat van het bestek wordt afgeweken.

Dat de offerte na-BAFO van CFE-Blaton geen invloed zou hebben gehad op de rangschikking zoals de verwerende partij beweert in de memorie van antwoord, gaat niet op. Dit kan immers niet worden nagegaan nu er sprake is van niet te vergelijken offertes. Er kan niet worden uitgesloten dat de inkorting van de uitvoeringstermijn en de wijziging van de mijlpalen aanzienlijke invloed hebben gehad op de globale beoordeling van de planning van CFE-Blaton in vergelijking met de planning die in haar BAFO was ingediend. Bovendien geldt dat CFE-Blaton zowel in haar BAFO als in haar offerte na-BAFO in de planning geen rekening heeft gehouden met mijlpaal T1+18 terwijl in het bestek uitdrukkelijk werd voorgeschreven dat de inschrijvers deze mijlpaal moesten naleven. Ook om die reden kan niet worden volgehouden dat de offerte na-BAFO geen invloed zou hebben gehad op de uiteindelijke rangschikking, nu de planning in elk geval niet beantwoordde aan de besteksvereisten. De verwerende partij heeft onvergelykbare offertes met elkaar vergeleken.

14. In hun laatste memorie blijven de verzoekende partijen erbij dat na de BAFO-fase geen onderhandelingen meer mogen worden gevoerd met de inschrijvers en de inschrijvers hun reeds ingediende BAFO niet meer mogen wijzigen. Op grond van de duidelijke tekst van artikel 2.10 van het bestek ligt het volgens hen dus vast dat het de verwerende partij niet is toegestaan na de indiening van de BAFO nog onderhandelingen te voeren met de inschrijvers, dit omdat de BAFO de definitieve en finale offerte is van de inschrijver. Het feit dat het bestek in artikel 1.2 voorschrijft dat de opdracht wordt gegund met een onderhandelingsprocedure met bekendmaking en aangeeft waarop de onderhandelingen inhoudelijk betrekking kunnen hebben, dient aldus te worden gelezen in functie van het procedureverloop dat in artikel 2.10 van het bestek is voorgescreven en zoals ook uitdrukkelijk in artikel 1.2 van het bestek aangekondigd. Dit artikel bepaalt namelijk dat “tijdens deze vergaderingen de aanbestedende overheid het accent [zal] leggen op de voornaamste elementen die in de offerte eventueel nog kunnen verbeterd worden”. Aangezien het bestek in artikel 2.10 voorschrijft dat de BAFO’s als finaal beoordelingselement voor de opmaak van de eindrangschikking zullen dienen, bepaalt artikel 1.2 aldus zelf uitdrukkelijk dat de verwerende partij maar met de inschrijvers kan onderhandelen tot op het ogenblik van de indiening van de BAFO. De mogelijkheid om verduidelijkingen na de indiening van een BAFO te vragen betekent, aldus de verzoekende partijen, niet dat een inschrijver, in weerwil van de duidelijke bepalingen van het bestek, nog bijkomende documenten mag indienen die zijn eerder ingediende BAFO wijzigen. De gekozen inschrijver heeft niet enkel verduidelijkingen met betrekking tot haar BAFO aan verwerende partij verschaft, maar tevens bijkomend een gewijzigde planning, een aangepast prijsvoorstel en een “lettre d’engagement”.

Beoordeling

15. Artikel 5 van de wet overheidsopdrachten 2006 luidt:

“De aanbestedende overheden behandelen de aannemers, de leveranciers en de dienstverleners op gelijke, niet-discriminerende en transparante wijze.

De overheidsopdrachten worden gegund na mededinging, na verificatie van het toegangsrecht, kwalitatieve selectie en onderzoek van de offertes van de deelnemers, overeenkomstig één van de in hoofdstuk IV bepaalde gunningsprocedures.”

Artikel 55 van de voormelde wet maakt deze bepaling van toepassing op overheidsopdrachten in de sector vervoer.

Artikel 106 van het van het koninklijk besluit plaatsing speciale sectoren luidt:

“Bij een onderhandelingsprocedure wordt de opdracht gegund, hetzij aan de inschrijver die de laagste offerte heeft ingediend, hetzij aan de inschrijver die de offerte heeft ingediend die de economisch voordeligste is vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, rekening houdend met de gunningscriteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht en een objectieve vergelijking mogelijk maken op basis van een waardeoordeel. In dit laatste geval, wanneer het gaat om een opdracht die de drempel vermeld in artikel 32 bereikt, specificeert de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten de weging van elk gunningscriterium. Deze weging kan eventueel worden uitgedrukt binnen een vork met een passend verschil tussen minimum en maximum. Indien een dergelijke weging om aantoonbare redenen niet mogelijk is, worden de criteria vermeld in dalende volgorde van belangrijkheid.

Het vorige lid is niet toepasselijk op :

1°de opdrachten voor diensten bedoeld in bijlage II, B, van de wet;

2°de diverse gevallen van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarvoor slechts één aannemer, leverancier of dienstverlener kan worden geraadpleegd;

3°de opdrachten geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met toepassing van artikel 53, § 2, 1°, a), van de wet;

4°voor zover ze de drempel van artikel 32 niet bereiken, de opdrachten geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met toepassing van artikel 53, § 2, 1°, c), en 4°, c) tot e), van de wet.”

Het bestek vermeldt het volgende onder “1.2. Gunningswijze”:

“1.2 Gunningswijze

In toepassing van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten en van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2012 betreffende de gunning van de overheidsopdrachten in de speciale sectoren zal de opdracht gegund worden d.m.v. een onderhandelings-procedure met publicatie, overeenkomstig de principes vermeld in bepaling 2.10.

Deze procedure zal voor de inschrijvers zo economisch en doeltreffend mogelijk verlopen. Men zal er hierbij over waken dat de gelijkheid tussen de inschrijvers strikt nageleefd wordt.

Tijdens de onderhandelingen kunnen inschrijvers gezamenlijk of afzonderlijk, maar in gelijkaardige omstandigheden, ontvangen worden door een delegatie van de MIVB en van de vertegenwoordigers en raadgevers ervan.

Tijdens deze eventuele vergaderingen:

- krijgt de inschrijver de gelegenheid om de sterke punten van zijn offerte te benadrukken;
- zal de inschrijver eventueel verzocht worden om de technische, administratieve en financiële aspecten van zijn offerte verder toe te lichten.

Tijdens deze vergaderingen zal de aanbestedende overheid het accent leggen op de voornaamste elementen die in de offerte eventueel nog kunnen verbeterd worden.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om op elk moment te opteren om de onderhandelingen verder te zetten met alle inschrijvers of met bepaalde inschrijvers in functie van de voorlopige resultaten. De aanbestedende overheid kan echter, op ieder ogenblik, de onderhandelingen met de andere inschrijvers hervatten.

De communicatie met de inschrijvers kan tijdens de onderhandelingen zowel schriftelijk, door verzending van een brief per post, per fax of via elektronische weg verlopen.

Deze benadering moet er in essentie voor zorgen dat noch de inschrijvers, noch de aanbestedende overheid tot grote en nutteloze kosten zouden gedwongen worden.”

In hoofdstuk “2.10 Gunningscriteria” van het bestek wordt bepaald:

“Aan het einde van de analyse van de First Offer en van eventuele onderhandelingen en/of van verduidelijkingen zal de aanbestedende overheid een voorlopige rangschikking van de offertes opstellen. Hij zal

maximum 3 inschrijvers weerhouden die desgevallend verzocht zullen worden te onderhandelen en vervolgens een BAFO in te dienen.

Aan het einde van de analyse van de BAFO zal de aanbestedende overheid een eindrangschikking van de offertes opstellen op basis van een volledige toepassing van de gunningscriteria.”

16. Uit artikel 1.2 blijkt dat de verwerende partij zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om “op elk moment” de onderhandelingen verder te zetten, met alle of bepaalde inschrijvers.

Uit de voormelde besteksbepalingen blijkt alleszins geen expliciet en ondubbelzinnig totaalverbod op contactname met de inschrijvers na het indienen van de BAFO's. De verwijzing naar “de analyse van de BAFO's” laat integendeel eerder een opening voor de aanbestedende overheid om verduidelijking of verdere aanvulling aan de inschrijvers te vragen. Daarbij dient de aanbestedende overheid dan wel de gelijkheid tussen de inschrijvers te waarborgen.

De op 18 december 2015 door de verwerende partij opgestuurde lijst met vragen en opmerkingen (“troisième liste de questions/informations concernant l’analyse de votre BAFO”) bij de analyse van hun BAFO's werd aan de drie nog betrokken inschrijvers verzonden en bevat onder meer wat ID 2180 betreft:

“Création d’un terminus en avant-gare de la station Erasme AVANT d’entamer les travaux d’arrière gare:

La STIB va créer le terminus en avant-gare de la station Erasme en ajoutant une communication et des butoirs provisoires (qui seront réutilisés pour la voie d'essai). Cela veut dire que le choix du quai de départ / d'arrivée sera fait avant d'arriver dans la station et non plus après comme actuellement. La fin de ces travaux est prévue en décembre 2017. A partir de ce moment, le travail en arrière-gare sera possible sans plus aucune contrainte d'exploitation (pas de rames, pas de 900V,...). Le risque d'interférence de l'exploitation avec le chantier sera donc quasiment nul. Nous partons du principe que votre planning pourra, le cas échéant, être adapté en fonction de cette nouvelle donnée.”

[Vertaling: Creatie van een eindstation vóór de halte Erasmus vooraleer de werken aan te vatten het achterstation:

De MIVB zal een eindstation creëren vóór de halte Erasmus d.m.v. de installatie van een wissel en voorlopige stootblokken (die hergebruikt zullen worden voor het testspoor). Dit betekent dat de keuze van het vertrek- of aankomstperron zal gemaakt worden alvorens de halte binnen te rijden en niet meer erna zoals momenteel voorzien. Het einde van deze werken is voorzien voor eind december 2017. Vanaf dat moment kunnen de werken in het achterstation uitgevoerd worden zonder enige belemmering ten gevolge van de exploitatie (geen metrostellen, geen 900V, ...). Het risico van interferentie tussen de exploitatie van de metrolijn en de werf zal dus zo goed al nul zijn. Wij vertrekken van het principe dat uw planning, in voorkomend geval, kan worden aangepast in functie van dit nieuwe gegeven.]

En wat ID 2208 betreft:

“Veuillez noter que le jalon demandant un accès au dépôt pour les 5 premiers trains en T0+18 mois est supprimé.”

[vertaling: Gelieve te noteren dat de mijlpaal die een toegang tot de stelplaats vraagt voor de 5 eerste metrostellen op T0 [lees: T1] + 18 maanden, vervalt.]

De verzoekende partijen blijken daarop op 20 januari 2016 het volgende antwoord aan de verwerende partij te hebben gestuurd bij ID 2180:

“Notre planning pourra effectivement être adapté en fonction de cette nouvelle contrainte spatiale et temporelle.

Cette adaptation tiendra aussi compte de la question 2208 (suppression du jalon), ainsi que de la date de démarrage en lien avec la question 2198 (trajet de la procédure).”

[vertaling: Onze planning kan effectief worden aangepast in functie van deze nieuwe beperking in tijd en ruimte.

Deze aanpassing zal ook rekening houden met de vraag 2208 (weglaten van de mijlpaal), alsook met de begindatum verbonden met vraag 2198 (traject van de procedure).]

En het antwoord op ID 2208:

“Nous prenons bonne note de cette information.”

[vertaling: Wij nemen akte van deze inlichting.]

De gekozen inschrijver heeft daarop op 20 januari 2016 het volgende antwoord aan de verwerende partij gestuurd, wat ID 2180 betreft:

“A la BAFO, nous avons étudié une solution (voir notes phasage et annexes B & C) permettant de maintenir l'exploitation de l'arrière gare jusque T1+18 mois.

Cette solution entraînait notamment l'exécution de parois en soilmix, dont le coût a été évalué au § 2.2 'note explicative' de notre BAFO.

La suppression de cette contrainte permet de faciliter notre organisation de chantier et de réduire nos coûts d'exécution d'un montant de 356600 € (en phase 1).”

[vertaling: In de BAFO hebben wij een oplossing [...] bestudeerd die toeliet de exploitatie van het achterstation te behouden tot T1 +18 maanden. Deze oplossing bracht met zich mee [...], waarvan de kosten werden geëvalueerd in § 2.2. verklarende nota van onze BAFO.

De weglating van deze beperking laat toe de organisatie van onze werf te vergemakkelijken en onze kosten van uitvoering te verminderen met een bedrag van 356.600 € (in fase 1).]

En wat betreft ID 2208:

“Bien noté. La prise en compte de cette donnée, ainsi que de nouvelles hypothèses reprises sous le point ID 2181, nous permet d'optimiser le planning d'exécution de 18 J.C., de réorganiser notre chantier et de réduire nos coûts d'exécution d'un montant de 361700 € (en phase 1) . La liste des nouvelles dates jalons est jointe en annexe.”

[vertaling: Goed genoteerd. Het in aanmerking nemen van dit gegeven evenals de nieuwe hypothesen hernomen onder punt ID 2181 laat ons toe om de uitvoeringsplanning te optimaliseren met 18 K.D., om onze werf te reorganiseren en om de uitvoeringskosten te verminderen met een bedrag van 361.700 € (in fase I). De lijst van nieuwe mijlpaaldata is als bijlage opgenomen.]

17. De verzoekende partijen tonen niet aan waarom de verwerende partij, door na het indienen van de BAFO's aan de inschrijvers nog deze vragen en opmerkingen te bezorgen, de bepalingen van het bestek zou hebben miskend.

Bovendien dient deze mededeling over de creatie tegen eind december 2017 van een eindstation vóór de halte Erasmus – zodat vanaf die datum de werken in het achterstation kunnen worden uitgevoerd zonder enige

exploitatiebelemmering – en de afschaffing van de mijlpaal T1+18m samen gezien te worden met de – in de bewoordingen van de verwerende partij – “belangrijke informatie” die zij de inschrijvers reeds meedeelde op 15 juni 2015, dit is na de indiening van de First Offers en vóór de indiening van de BAFO’s. De verwerende partij deelde toen aan de inschrijvers mee dat zij bij de voorbereiding van hun planning ermee rekening dienden te houden dat de sporen van het achterstation Erasmus zo laat mogelijk maar mochten worden betrokken en waarbij uitdrukkelijk werd gevraagd om “zo nodig” hun planning aan te passen. De verzoekende partijen gaan voorbij aan die “belangrijke informatie” die vóór de indiening van de BAFO’s werd meegedeeld en waarbij uitdrukkelijk werd gevraagd om daarmee rekening te houden in hun planning.

Uit de beoordeling van het subcriterium “fasering van de uitvoering en van de tussentijdse mijlpalen” blijkt ook dat de verwerende partij heeft onderzocht of effectief deze informatie door de inschrijvers werd geïntegreerd in hun planning; thans werd een planning waarbij de werken in de het achterstation zo laat mogelijk werden aangevat, beloond.

De thans betwiste informatie is in dat licht eigenlijk eerder een aanvulling, waarbij de verwerende partij aangeeft, enerzijds, een eindstation vóór de halte Erasmus te creëren, teneinde elk risico van interferentie tussen de exploitatie van de metrolijn en de werf te voorkomen en dit vanaf eind december 2017, en, anderzijds de mijlpaal T1+18m te laten wegvallen.

18. Voorts kan de veronderstelling van de verzoekende partijen dat de gekozen inschrijver, met zijn antwoord, “een volledig nieuwe offerte na-BAFO [heeft] ingediend met fundamentele herziening van planning en prijs”, niet worden bijgevalen.

Noch uit het administratief dossier, noch uit de vertrouwelijke stukken ervan, blijkt dat de gekozen inschrijver na het indienen van zijn BAFO

een volledig nieuwe “derde” offerte zou hebben ingediend. In die mate berust het middel alvast op een onjuist feitelijk uitgangspunt.

De gekozen inschrijver blijkt enkel in het licht van de voormelde mededelingen van de verwerende partij van 18 december 2015 in zijn antwoord van 20 januari 2016 te kennen hebben gegeven dat deze aanpassingen naast een “optimalisering” van zijn uitvoeringstermijn met 18 kalenderdagen ook een verlaging van zijn uitvoeringskosten met zich meebrengt.

De verwerende partij merkt terecht op dat de gekozen inschrijver zich met dit antwoord niet verbindt op dezelfde wijze als door het indienen van zijn BAFO. De verwerende partij blijkt met de voorgestelde optimalisering en prijsaanpassing ook geen rekening te hebben gehouden bij de eindbeoordeling van de BAFO's. Het administratief dossier bevestigt inderdaad dat de verwerende partij bij de toetsing van de BAFO's aan de gunningscriteria geen rekening heeft gehouden met de voorgestelde prijsverlaging – die prijsverlaging wordt alleszins niet betrokken in het stuk “financieel nazicht BAFO's”, noch wordt ze vermeld in enig ander stuk van het administratief dossier, laat staan in de bestreden beslissing. Ook wat de uitvoeringstermijn betreft, blijkt de bestreden beslissing de uitvoeringstermijn voorgesteld in de BAFO van de gekozen inschrijver te hanteren en niet de geoptimaliseerde uitvoeringstermijn zoals vermeld in bijlage bij het antwoord van de gekozen inschrijver van 20 januari 2016. De vermelding in de bestreden beslissing – namelijk dat er een reeks vragen werd gesteld aan de drie inschrijvers, “waarop ze allen hebben geantwoord binnen de gestelde termijn” en dat deze deel uitmaken “van de offertedocumenten die door de aanbestedende overheid geëvalueerd werden” – waar de verzoekende partijen naar verwijzen in de memorie van wederantwoord, doet aan deze vaststellingen geen afbreuk.

Overigens mag worden opgemerkt dat het, anders dan wordt beweerd in de memorie van wederantwoord, zowel wat de reductie van uitvoeringstermijn – ongeveer 2% – als de aanpassing van de totale offerteprijs –

minder dan een 0,5% – betreft, om veeleer geringe aanpassingen gaat, en dus bezwaarlijk om “fundamentele wijzigingen” aan de BAFO. Ten overvloede, het blijkt niet dat deze uitermate beperkte aanpassingen de rangschikking van de offertes op enige substantiële wijze zouden hebben beïnvloed, zelfs indien de verwerende partij er toch rekening mee zou hebben gehouden bij de finale beoordeling van de offertes.

19. Betreffende de grief inzake het bezorgen van een “lettre d’engagement” over het gebruik van aan de werfsite palende terreinen, dient met de verwerende partij te worden vastgesteld dat uit de BAFO van de gekozen inschrijver blijkt dat deze met zijn werfinrichting binnen de werfzone zal blijven en in beginsel geen bijkomende gronden zal nodig hebben. In antwoord op een vraag die de aanbestedende overheid aan de drie overblijvende inschrijvers heeft gesteld in haar schrijven met vragen en opmerkingen van 18 december 2015, namelijk te bevestigen dat er geen meerprijs zal worden aangerekend of een termijnverlenging zal worden gevraagd indien niet tot een overeenkomst kan worden gekomen met de eigenaars van aanpalende gronden, heeft de gekozen inschrijver een verbintenis voorgelegd van de eigenaar van een aanpalend grondstuk ‘Erasmus Gardens’, inhoudend dat deze, indien nodig, een deel van zijn terreinen ter beschikking wil stellen. Er blijkt niet hoe deze handelwijze de in het middel ingeroepen bepalingen en beginselen zou miskennen.

20. De argumentatie in de memorie van wederantwoord dat de aanbestedende overheid zelf impliciet had bevestigd dat er geen aangepaste planning mocht worden ingediend, blijkt voorts feitelijke grond te missen. In haar schrijven met vragen en opmerkingen van 18 december 2015 blijkt de verwerende partij immers wel degelijk alle inschrijvers hetzelfde mee te delen: “Wij vertrekken van het principe dat uw planning, in voorkomend geval, kan aangepast worden in functie van dit nieuwe gegeven.” Er blijkt niet hoe een vermelding in een later schrijven, zoals de verzoekende partijen doen gelden, “dat kolom G ‘bij te voegen documenten’ niet moest worden ingevuld door de

inschrijvers” afbreuk zou doen aan die expliciete uitnodiging tot eventuele aanpassing van de planning.

21. Ten slotte, wat de kritiek in de memorie van wederantwoord betreft dat de planning van de gekozen inschrijver reeds in de BAFO geen rekening zou hebben gehouden met mijlpaal T1+18, dient te worden vastgesteld dat het gaat om een grief die meer uitgebreid in het debat wordt gebracht onder het vierde middel. Er wordt verwezen naar het onderzoek van dat middel.

22. Het middel wordt verworpen.

B. Tweede middel

Uiteenzetting van het middel

23. De verzoekende partijen voeren de schending aan van artikel 5 *juncto* artikel 55 van de wet overheidsopdrachten 2006, artikel 106 van het koninklijk besluit plaatsing speciale sectoren, van artikel 10 en 11 van de grondwet alsook van het algemeen beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie en van het transparantiebeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Zij achten deze bepalingen en beginselen geschonden:

“Doordat verwerende partij naar aanleiding van de mededeling op 18 december 2015 aan verzoekende partijen (en evenmin aan inschrijver Franki Construct-Jan De Nul) niet de kans heeft geboden een aangepaste planning in te dienen;

Terwijl inschrijver CFE-Blaton wel een aangepaste planning heeft ingediend (offerte na-BAFO) en verwerende partij hiermee rekening heeft gehouden bij de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria;

En terwijl het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel vereisen dat alle inschrijvers gelijk worden behandeld en zij op basis van dezelfde informatie een offerte kunnen indienen;

Zodat vaststaat dat de aangehaalde bepalingen en beginselen zijn geschonden.”

De verzoekende partijen lichten toe dat de verwerende partij op 18 december 2015 aanvullende informatie aan de inschrijvers bezorgde inzake de planning van de werken. Het bestek liet niet toe dat een gewijzigde planning zou worden ingediend en bepaalde dat enkel de BAFO als finaal beoordelingselement zou dienen. Niet enkel de verzoekende partijen maar ook de inschrijver Franki Construct-Jan De Nul oordeelden terecht dat geen gewijzigde planning mocht worden ingediend. Aldus mag de mededeling van de verwerende partij van 18 december 2015 niet worden beschouwd als een uitnodiging om een aangepaste planning in te dienen. Het gaat volgens de verzoekende partijen enkel om een loutere veronderstelling waarbij de verwerende partij doelde op een wijziging van de planning in het kader van de uitvoering van de werken. Het mag de verzoekende partijen niet ten kwade worden geduid dat zij zich aan de bepalingen van het bestek hebben gehouden en geen offerte na-BAFO hebben ingediend. De aanvullende informatie van 18 december 2015 mocht niet worden beschouwd als een formele notificatie van de heropening van de BAFO-fase en een formeel verzoek om, gelet op de substantiële impact van het wegvallen van de tussenmijlpaal T1+18 maanden, een offerte na-BAFO met aangepaste planning en prijs in te dienen.

Het feit dat de verwerende partij geconfronteerd werd met twee inschrijvers – de verzoekende partijen en Franki Construct-Jan De Nul – die de mededeling niet hadden begrepen als een uitnodiging om een aangepaste planning in te dienen en met één inschrijver – CFE-Blaton – die wél een gewijzigde planning indiende, had de verwerende partij ertoe moeten aanzetten om de verzoekende partijen en Franki Construct-Jan De Nul alsnog uitdrukkelijk uit te nodigen om een aangepaste planning in te dienen, dan wel geen rekening te houden met de offerte na-BAFO van CFE-Blaton. De verwerende partij had moeten vaststellen dat haar mededeling niet transparant was. Door de verzoekende partijen en Franki Construct-Jan De Nul niet deze kans te bieden, wetende dat hun plannings nog konden worden aangepast, heeft de verwerende

partij het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel geschonden. Indien de verwerende partij de verzoekende partijen voldoende nauwkeurig zou hebben ingelicht, zouden de verzoekende partijen eveneens een offerte na-BAFO hebben ingediend en hadden zij mogelijk een betere score gekregen.

24. In de memorie van wederantwoord benadrukken de verzoekende partijen dat hun middel zich richt op “de duidelijke afwezigheid van de vereiste transparantie en bijgevolg de schending van het transparantiebeginsel”.

Voorts wijzen zij erop dat het document dat de verwerende partij op 18 december 2015 aan de inschrijvers ter beschikking stelde een excel-bestand betrof met twee kolommen: één voor vragen en één voor antwoorden. De verzoekende partijen hebben op deze vragen geantwoord en hebben dit bericht beschouwd als een uitnodiging om te reageren, zonder het te beschouwen als een uitnodiging om de BAFO en in het bijzonder de planning te wijzigen. De verzoekende partijen hebben bevestigd dat hun planning kon worden aangepast. Zij hebben hun BAFO niet aangepast, nu dit niet werd gevraagd door de verwerende partij. Het document van 18 december 2015 betreft volgens de verzoekende partijen een loutere stellingname zonder een daadwerkelijke uitnodiging voor de inschrijvers om hun BAFO aan te passen. Daarenboven moet worden aangenomen dat met de woorden “in voorkomend geval” de verwerende partij van de inschrijvers enkel de bevestiging wenste te verkrijgen dat hun planning al dan niet kon worden aangepast, waarna de verwerende partij een bijkomend moment zou organiseren voor de inschrijvers om hun BAFO aan te passen.

Volgens de verzoekende partijen erkent de verwerende partij in haar memorie van antwoord zelf dat zij met haar mededeling van 18 december 2015 de inschrijvers niet heeft uitgenodigd om hun BAFO aan te passen. Zij ontkent immers niet dat deze mededeling niet als een uitnodiging tot het indienen van een nieuwe planning kon worden beschouwd, maar geeft daarentegen aan dat CFE-Blaton dit heeft begrepen als een uitnodiging om een offerte na-BAFO in te dienen. Daarbij bevestigt de verwerende partij bovendien dat CFE-Blaton wel

degelijk haar planning heeft gewijzigd, zodat niet kan worden betwist dat CFE-Blaton een offerte na-BAFO heeft ingediend. Het is pas nadat de verwerende partij de antwoorden van de inschrijvers heeft ontvangen, dat zij oordeelde dat CFE-Blaton een nieuwe planning mocht voorstellen. In die zin kan het de verzoekende partijen niet worden verweten dat zij hun planning niet hebben aangepast, nu de verwerende partij dit niet zelf heeft vooropgesteld toen zij de lijst met vragen en opmerkingen aan de inschrijvers bezorgde.

Dat de verzoekende partijen zorgvuldig hebben gehandeld wordt, aldus de verzoekende partijen, bevestigd doordat zij op 11 januari 2016 een e-mailbericht hebben gestuurd aan de verwerende partij met de vraag of bijkomende of nieuwe documenten mochten worden ingediend naar aanleiding van de nieuwe informatie van 18 december 2015 en het bericht van de verwerende partij van 7 januari 2016. De verwerende partij heeft nooit gereageerd op dit e-mailbericht. Omdat de verwerende partij bij bericht van 7 januari 2016 te kennen had gegeven dat met betrekking tot deze vragenlijst kolom G “Fichiers a joindre” (“bij te voegen bestanden”) niet voor de inschrijvers bestemd was, “oordeelden” de verzoekende partijen in alle redelijkheid en zorgvuldigheid dat evenmin met betrekking tot de vragen van 18 december 2015 bijkomende of nieuwe documenten mochten worden ingediend.

Voor zover de verwerende partij van oordeel was dat CFE-Blaton inderdaad een gewijzigde planning mocht voorstellen, terwijl zij dit niet bedoelde met haar mededeling van 18 december 2015 en dit ook zo niet begrepen was door twee van de drie inschrijvers, had de verwerende partij ook aan de twee andere inschrijvers de mogelijkheid moeten bieden om een aangepaste planning in te dienen, dan wel had zij de BAFO-fase moeten heropenen. De nieuwe informatie van 18 december 2015 was immers cruciaal bij de opmaak van de planning. De discretionaire bevoegdheid waarover een aanbestedende overheid beschikt in een onderhandelingsprocedure is geen vrijgeleide voor haar om achteraf te beslissen welke draagwijdte zij aan een mededeling zal geven, zonder alle inschrijvers op de hoogte te brengen van de – achteraf besliste – draagwijdte

van de mededeling. De stelling van de verwerende partij dat het gelijkheidsbeginsel niet zou toelaten om na het indienen van de antwoorden van 20 januari 2016 de inschrijvers nog de mogelijkheid te bieden een aangepaste planning in te dienen, strookt niet met het grondwettelijk gewaarborgd principe van de gelijke behandeling van de inschrijvers, dat er volgens de verzoekende partijen juist toe leidt dat de verwerende partij de andere inschrijvers dezelfde mogelijkheid had moeten bieden om de planning aan te passen in functie van de nieuwe gegevens.

Het feit dat het bestek niet uitsluit dat na de BAFO's nog wijzigingen aan de offertes zouden worden aangebracht, is geen vrijgeleide voor de verwerende partij om het procedureverloop willekeurig te wijzigen in functie van één inschrijver. In zoverre de verwerende partij mocht oordelen dat de inschrijvers een offerte na-BAFO mochten indienen omwille van de nieuwe informatie met betrekking tot de werken in het achterstation en het wegvallen van mijlpaal T1+18, diende zij in elk geval eveneens de twee andere inschrijvers dezelfde mogelijkheid te bieden. De verzoekende partijen ontkennen dan ook dat zij bewust een kans zouden hebben laten voorbijgaan om een aangepaste planning in te dienen; zij verwijten daarentegen de verwerende partij bewust de gelijke behandeling van de inschrijvers te hebben miskend.

In zoverre de Raad van State van oordeel zou zijn dat de transparantieplichting en het beginsel van de gelijke behandeling niet zo ver zouden reiken dat een aanbestedende overheid ook de andere inschrijvers moet uitnodigen om hun offerte aan te passen, wanneer zij van mening was dat een inschrijver gerechtigd was dit te doen naar aanleiding van een vraag van de aanbestedende overheid, vragen de verzoekende partijen om de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie:

“Dient het beginsel van gelijke behandeling, en meer in het bijzonder het transparantiebeginsel dat daaruit voortvloeit, te worden uitgelegd in die zin dat voor een aanbestedende overheid de verplichting geldt om, wanneer één inschrijver op basis van een vragenlijst van de aanbestedende overheid zijn reeds ingediende Best-and-Final Offer (BAFO) wijzigt, en de aanbestedende overheid voornemens is de gewijzigde BAFO mee te

nemen in de beoordeling van de inschrijvingen, eveneens aan de andere inschrijvers, die de vragenlijst niet hebben begrepen als een uitnodiging om de BAFO te wijzigen, de kans te geven een gewijzigde BAFO in te dienen?”

25. In hun laatste memorie blijven de verzoekende partijen erbij dat de verwerende partij wel degelijk meer had moeten doen om de verzoekende partijen – alsook inschrijver Franki Construct - Jan De Nul – toe te laten eveneens de bij BAFO ingediende planning aan te passen en naar aanleiding daarvan eventueel ook een nieuw prijsvoorstel te formuleren en tevens dat het schrijven van 18 december 2015 geenszins als een daadwerkelijke uitnodiging kon worden beschouwd om de uitvoeringsplanning aan te passen en ook een aangepaste kostenberekening te bezorgen. In het voormelde schrijven deelde de verwerende partij enkel mee dat “wij vertrekken van het principe dat uw planning, in voorkomend geval, kan aangepast worden in functie van dit nieuwe gegeven”. De verzoekende partijen menen dat deze zinsnede op geen enkele wijze als een duidelijke en niet voor interpretatie vatbare vraagstelling of uitnodiging mag worden beschouwd om daadwerkelijk een gewijzigde planning in te dienen. De verzoekende partijen stelden daartoe op 11 januari 2016 een duidelijke vraag aan de verwerende partij, waarop zij geen enkel antwoord ontvingen, zodat zij finaal oordeelden dat het hun niet was toegestaan om naast het formuleren van een eenvoudig antwoord op de vragen van de verwerende partij ook bijkomende documenten te bezorgen. Bij de nog op 7 januari 2016 bezorgde bijkomende vragenlijst gaf de verwerende partij ook duidelijk aan dat “ter verduidelijking, kolom G ‘Bij te voegen documenten’ niet van belang [is] in het kader van deze vragenlijsten”.

De verzoekende partijen verwijzen voorts naar rechtspraak van de Raad van State, betreffende de situatie waarbij tijdens de onderhandelingen werd vastgesteld dat een onduidelijkheid was ontstaan over een besteksbepaling en die bepaling niet door alle inschrijvers op dezelfde wijze was geïnterpreteerd. Zij verwijzen ook nog naar een arrest van de Raad waarin kritiek werd geuit op het feit dat in het kader van een onderhandelingsprocedure aan enkele

inschrijvers tijdens de eerste onderhandelingsronde werd meegedeeld voor welke post zij een verbeterd voorstel dienden te formuleren, terwijl een andere inschrijver – in die zaak de verzoekende partijen – in het kader van de tweede onderhandelingsronde weliswaar een BAFO mocht indienen maar zonder dat aan hem gelijkaardige informatie werd meegedeeld omtrent de posten die tot een verbeterd voorstel zouden kunnen leiden.

De verzoekende partijen handhaven tenslotte hun verzoek tot prejudiciële vraagstelling. Het Europees Hof van Justitie kan zich volgens hen wel degelijk zinvol uitspreken over de vraag of het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel, zoals die voortvloeien uit de artikelen 49 en 56 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, inhouden dat een aanbestedende overheid, zoals de verwerende partij, ook de andere inschrijvers moet uitnodigen om hun offerte aan te passen wanneer zij van mening was dat een inschrijver daartoe gerechtigd was.

Beoordeling

26. Bij het onderzoek van het eerste middel werd reeds vastgesteld dat de verwerende partij aan alle inschrijvers dezelfde vragen en antwoorden blijkt te hebben voorgelegd. Anders dan de verzoekende partijen doen gelden in het verzoekschrift blijkt het bestek niet uit te sluiten dat de aanbestedende overheid tijdens de analyse van de BAFO's nog bepaalde aanvullingen en verduidelijkingen zou vragen aan de inschrijvers – zoals ook reeds vastgesteld bij het onderzoek van het eerste middel. Eveneens anders dan de verzoekende partijen betogen en eveneens reeds vastgesteld bij het onderzoek van het eerste middel, mag het schrijven met vragen en opmerkingen van 18 december 2015 van de aanbestedende overheid als voldoende transparant worden beschouwd zodanig dat een normaal zorgvuldig inschrijver bij de lezing ervan redelijkerwijs diende te weten dat hem de voornoemde mogelijkheid werd geboden (“Wij vertrekken van het principe dat uw planning, in voorkomend geval, kan aangepast worden in functie van dit nieuwe gegeven”). Met de woorden “in voorkomend

geval” wordt eerder ‘indien nodig’ bedoeld, namelijk wanneer een inschrijver in zijn planning inderdaad de uitvoering van werken in het achterstation voorziet op een tijdstip vóór eind december 2017, terwijl nadien een wisselspoor vóór de halte Erasmus zal zijn gecreëerd zodat vanaf dat tijdstip de werken in het achterstation kunnen worden uitgevoerd zonder enige belemmering ten gevolge van de exploitatie van dat achterstation.

De verzoekende partijen tonen niet aan dat zij niet met een eenvoudig antwoord zouden kunnen aangeven hoe hun planning effectief aan dat nieuwe gegeven zou kunnen worden aangepast.

Bovendien werd er reeds bij het onderzoek van het eerste middel op gewezen dat het betrokken schrijven van de verwerende partij eigenlijk een aanvulling vormde op de “belangrijke informatie” reeds meegedeeld op 15 juni 2015, vóór het indienen van de BAFO’s, dat de inschrijvers in hun planning moeten rekening houden met de behoeften van de MIVB op het vlak van het zo lang mogelijk exploiteerbaar blijven van het achterstation aan de halte Erasmus.

Het betoog in de memorie van wederantwoord dat de informatie van 18 december 2015 “cruciaal” was voor het opmaken van een nieuwe planning, kan alleen al in het licht van de voorgaande vaststelling met betrekking tot die reeds meegedeelde “belangrijke informatie”, niet worden bijgevalen. De verzoekende partijen hebben immers blijkbaar hun planning, zoals zij zelf in hun andere middelen beweren, niet echt gewijzigd ten opzichte van hun First offer, niettegenstaande de verwerende partij haar verwachtingen op het vlak van de zo lang mogelijke beschikbaarheid van het achterstation reeds met die voormelde informatie van 15 juni 2015 had kenbaar gemaakt en eigenlijk aanvullend met die mededelingen van 18 december 2015 aangeeft dat zij die beschikbaarheid zoveel mogelijk wil laten garanderen tot eind december 2017.

Voorts zal het betoog inzake het beweerde allesbepalende belang van tussenmijlpaal T1+18 hierna worden onderzocht bij het vierde middel.

27. Bovendien, zoals reeds vastgesteld bij het onderzoek van het eerste middel, werd in de bestreden beslissing rekening gehouden met de in de BAFO's voorgestelde uitvoeringstermijn en planningen. Er blijkt niet dat de verwerende partij met de lichtjes geoptimaliseerde uitvoeringstermijn/planning van de gekozen inschrijver heeft rekening gehouden. De gekozen inschrijver had reeds in zijn BAFO verbeteringsvoorstellen voorgesteld met betrekking tot de zo lang mogelijke beschikbaarheid van het achterstation. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de BAFO's die het best de verwachtingen van de MIVB meegedeeld met die voormelde informatie van 15 juni 2015 hebben geïntegreerd, het best scoren op dat derde subcriterium.

28. De door de verzoekende partijen voorgestelde prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie dient niet te worden gesteld omdat ze niet dienstig is voor de beoordeling van het middel.

De prejudiciële vraagstelling gaat er immers ten onrechte van uit dat de aanbestedende overheid de gewijzigde BAFO van één van de inschrijvers meeneemt in de beoordeling van de inschrijvingen, zonder ook de andere inschrijvers uit te nodigen om hun offerte aan te passen. Net is opnieuw vastgesteld dat dit te dezen niet is gebeurd.

29. Het middel wordt verworpen.

C. Derde middel

Uiteenzetting van het middel

30. De verzoekende partijen voeren de schending aan van artikel 106 van het koninklijk besluit plaatsing speciale sectoren, van artikel 4, 8°,

juncto artikel 5, 9°, van de wet van 17 juni 2013, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 ‘betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-handelingen’ (hierna: de wet van 29 juli 1991), van de materiële motiveringsplicht, van artikel 10 en 11 van de Grondwet, alsook van het algemeen beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie, van het beginsel *patere legem quam ipse fecisti* en van het zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Zij achten deze bepalingen en beginselen geschonden:

“Doordat verwerende partij de BAFO’s van de inschrijvers niet op gelijke wijze en in overeenstemming met de bepalingen van het bestek (met inbegrip van de bijkomende informatie) heeft beoordeeld, nu verwerende partij de bij beoordeling van het subgunningscriterium ‘fasering van de uitvoering en van de tussenmijlpalen’ onterecht rekening heeft gehouden met de uitvoering van de werken in het achterstation;

Terwijl een aanbestedende overheid, zoals verwerende partij, ertoe gehouden is om haar beoordeling van de ingediende offertes in het licht van de gunningscriteria en de beoordelingswijze opgenomen in het bestek te steunen op motieven die feitelijk juist en in rechte aanvaardbaar zijn, en dit met de rechtens vereiste zorgvuldigheid moet doen;

Zodat vaststaat dat de aangehaalde bepalingen en rechtsbeginselen zijn geschonden.”

De verzoekende partijen lichten toe dat de inschrijvers in het kader van het subgunningscriterium “fasering van de uitvoering en van de tussenmijlpalen” een planning dienden op te geven waarin zij moesten aantonen dat hun werken niet zouden interfereren met andere deelprojecten van het PULSAR-project. Op 15 juni 2015 bij de aanvang van de BAFO-fase deelde de verwerende partij aan de inschrijvers mee dat de werken in het achterstation bijzonder belangrijk waren bij de opmaak van de planning en zo laat mogelijk moesten worden uitgevoerd om de exploitatie van de metro zo lang mogelijk te kunnen garanderen. De verzoekende partijen hebben hun BAFO in die zin opgesteld, daarbij rekening houdend met de op dat ogenblik nog geldende tussenmijlpaal T1+18 op grond waarvan de eerste vijf opstelposities in de stelplaats ter

beschikking moesten worden gesteld. Op 18 december 2015, nadat de BAFO's waren ingediend, deelde de verwerende partij mee dat de werken in het achterstation geen invloed meer zouden hebben op de exploitatie van de metrostellen.

In de gunningsbeslissing wordt over de BAFO van de verzoekende partijen geoordeeld dat deze in een voortijdige interventie in het achterstation voorziet, wat een belangrijke verstoring van het metroverkeer met zich meebrengt vrij vroeg in de uitvoering – na acht maanden – wat een zware impact heeft op de exploitatie van lijnen 1 en 5. Met betrekking tot de BAFO van CFE-Blaton wordt geoordeeld dat deze inschrijver de verplichting tot beschikbaarheid van het achterstation, dat zo lang mogelijk exploiteerbaar moet blijven, goed geïntegreerd heeft en de zone van het achterstation slechts wordt aangepakt 17 maanden nadat het bevel tot aanvang van de werken is gegeven. Aldus heeft de verwerende partij alsnog rekening gehouden met de uitvoering van de werken in het achterstation. Bij de verzoekende partijen wordt dit als een minpunt beschouwd en bij CFE-Blaton als een bijzonder positief punt. Deze beoordeling in strijd met de door de verwerende partij zelf opgelegde regels gaat niet op. Het kan niet zijn dat, enerzijds, wordt meegedeeld dat er geen interferentie meer zal bestaan tussen de werken in het achterstation en de exploitatie van de metrostellen, maar de inschrijvers hier, anderzijds, wel op worden beoordeeld. De verwerende partij had bij de beoordeling van de fasering van de werken abstractie moeten maken van de werken in het achterstation, nu dit op grond van de mededeling van 18 december 2015 klaarblijkelijk geen beoordelingselement meer uitmaakte.

31. In de memorie van wederantwoord wijzen de verzoekende partijen erop dat de opdracht onder meer inhoudt dat een toegangshelling moet worden gebouwd in het achterstation om de metrostellen van het station Erasmus toegang te verschaffen tot de te realiseren stelplaats. De werken in het achterstation moeten zo worden gefaseerd dat op mijlpaal T1+18 de vijf eerste opstelposities aan de verwerende partij ter beschikking kunnen worden gesteld. In overeenstemming met het subgunningscriterium 'fasering van de uitvoerings-

planning en van de tussenmijlpalen' moesten de werken ook op die manier in de planning worden opgenomen.

De First Offer van de verzoekende partijen scoorde 30/30 voor het betrokken subgunningscriterium. De planning van CFE-Blaton kreeg daarentegen slechts 10/30. Op 15 juni 2015 deelde de verwerende partij aan de inschrijvers mee dat het bij de voorbereiding van de planning belangrijk is dat de sporen van het achterstation Erasmus zo laat mogelijk worden betrokken. De verwerende partij raakt in dit schrijven niet aan mijlpaal T1+18, die alsdan nog steeds geldt en moet worden gerespecteerd door de inschrijvers. De verzoekende partijen hebben hun BAFO aldus opgesteld rekening houdend met, enerzijds, het vereiste dat de werken in het achterstation zo laat mogelijk moeten worden betrokken en, anderzijds, het vereiste dat uiterlijk 18 maanden na de aanvang van de werken de eerste vijf opstelposities ter beschikking moeten worden gesteld (mijlpaal T1+18). De bewering van de verwerende partij dat zij geen enkele termijn of periode zou hebben gekoppeld aan het zo laat mogelijk betrekken van het achterstation is dan ook niet juist, aldus de verzoekende partijen. De verwerende partij gaat immers voorbij aan mijlpaal T1+18. De werken in het achterstation moesten dan wel zo laat mogelijk worden uitgevoerd, maar de inschrijvers moesten er wel over waken deze mijlpaal te respecteren. Uit geen enkel document blijkt het tegendeel. Aan de BAFO van de verzoekende partijen werd vervolgens slechts 12/30 toegekend voor het subgunningscriterium 'fasering van de uitvoeringsplanning en van de tussenmijlpalen', terwijl de verzoekende partijen een bijna identieke planning hebben ingediend in vergelijking met hun First Offer. De verwerende partij kent een score van 27/30 toe aan de BAFO van CIT-Blaton, terwijl de planning van deze inschrijver bij de First Offer maar 10/30 kreeg.

Uit de beoordeling in het gunningsverslag mag worden afgeleid dat de verwerende partij alsnog rekening heeft gehouden met de uitvoering van de werken in het achterstation in het geheel van de planning, terwijl zij per bericht van 18 december 2015 nog meedeelde dat er geen interferentie meer zal

bestaan tussen de werken in het achterstation en de exploitatie van de metro en bovendien mijlpaal T1+18 kwam te vervallen. Het is dan ook opmerkelijk, aldus de verzoekende partijen, dat de verwerende partij de BAFO's beoordeelt op grond van de werken in het achterstation en de interferentie met de exploitatie van de metro, terwijl zij zelf heeft aangegeven dat er geen interferentie meer zou bestaan omdat zij, enerzijds, zelf een nieuw eindstation zal creëren waarbij een wisselspoor vóór de halte Erasmus wordt aangelegd en omdat, anderzijds, mijlpaal T1+18 niet langer geldt en de werken in het achterstation niet meer moeten worden ingepland in functie van die mijlpaal. In overeenstemming met het bericht van 18 december 2015 had de verwerende partij moeten vaststellen dat de door de verzoekende partijen in hun planning voorgestelde werken in het achterstation niet langer zouden interfereren met de exploitatie van de metro, aangezien vanaf december 2017 de metrostellen niet langer in het achterstation zouden moeten komen om van spoor te wisselen. Dit geldt des te meer nu de verzoekende partijen in hun antwoord van 20 januari 2016 hebben aangegeven dat hun planning wel degelijk aan deze nieuwe informatie kon worden aangepast. De nieuwe informatie had tot gevolg dat de werken in het achterstation niet langer moesten worden uitgevoerd in functie van mijlpaal T1+18 die kwam te vervallen en bijgevolg op een later tijdstip zouden mogen worden uitgevoerd en zodoende er geen enkele interferentie meer zou bestaan met de exploitatie van de metro.

De verzoekende partijen hebben aldus onterecht te weinig punten gekregen nu volgens de eigen berichten van de verwerende partij er geen sprake zou zijn van interferentie tussen de werken in het achterstation en de exploitatie van de metro. De verzoekende partijen hadden minstens evenveel punten moeten krijgen als CFE-Blaton (27/30), omdat de interferentie van de werken in het achterstation niet kon worden meegenomen bij de beoordeling van de BAFO van de verzoekende partijen. Nu er slechts sprake was van een totaalverschil van 13 punten, had de opdracht bijgevolg aan de verzoekende partijen moeten worden toegekend, nu een stijging van 12 naar minstens 27 punten tot gevolg heeft dat de verzoekende partijen de hoogste totaalscore behalen.

De verwerende partij maakt, volgens de verzoekende partijen, in haar memorie van antwoord een kunstmatig en onterecht onderscheid tussen de invloed van de exploitatie op de werken in het achterstation en de invloed van de werken in het achterstation op de exploitatie. Dit onderscheid is irrelevant voor de vaststelling dat de verwerende partij in strijd met haar eigen berichten alsnog rekening heeft gehouden met de werken in het achterstation. Immers, het besluit van het bericht van 18 december 2015 is zonder meer dat ingevolge de creatie van een nieuw eindstation er geen interferentie meer zal zijn tussen de exploitatie van de metro, enerzijds, en de uitvoering van de werken in het achterstation, anderzijds. Met het bericht van 18 december 2015 geeft de verwerende partij aan dat de inschrijvers geen rekening meer moeten houden met de informatie van 15 juni 2015 inzake de zo laat mogelijke aanvang van de werken in het achterstation.

32. In hun laatste memorie blijven de verzoekende partijen bij hun kritiek dat de verwerende partij onterecht heeft vastgesteld dat volgens de planning van de verzoekende partijen de werken in het achterstation een impact zouden hebben op de exploitatie van de metrolijnen 1 tot 5. Zij benadrukken dat hun planning opgesteld was in functie van de naleving van mijlpaal T1+18, doch omdat deze mijlpaal ingevolge de mededeling van 18 december 2015 verviel, mocht de verwerende partij verzoekende partijen niet bestraffen omdat zij in haar BAFO met deze mijlpaal rekening had gehouden bij de opmaak van de planning, terwijl na indiening van de BAFO deze mijlpaal klaarblijkelijk niet meer van belang was en zij ook aangeven dat ingevolge daarvan hun planning zou kunnen worden aangepast.

De verzoekende partijen betwisten voorts dat zij in de memorie van wederantwoord een nieuwe kritiek zouden hebben ontwikkeld; zij hebben enkel toegelicht dat het opmerkelijk is dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de beoordeling van de planning door de verwerende partij in de First Offer en in de BAFO, terwijl de verzoekende partijen bij hun First Offer en hun BAFO

een bijna identieke planning hebben ingediend. Dit betreft volgens hen enkel een nadere feitelijke onderbouwing van de in dit middel aangevoerde schendingen.

Beoordeling

33. In zoverre het middel berust op een miskenning van de formelemotiveringsverplichting, dient op de eerste plaats te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing gemotiveerd is overheen 56 bladzijden. De verzoevende partijen hebben zowel in de procedure in kortgeding bij uiterst dringende noodzakelijkheid als thans in de procedure ten gronde uitvoerig inhoudelijk uitgewerkte middelen tot nietigverklaring ten aanzien van die beslissing kunnen doen gelden. In de onderhavige procedure zijn de verzoevende partijen in staat geweest om een verzoekschrift van 55 bladzijden en een memorie van wederantwoord van 148 bladzijden in te dienen met daarin vijf middelen tot nietigverklaring, ondersteund met een voorstel tot prejudiciële vraagstelling aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, een uitvoerig voorstel tot het aanstellen van een deskundige en een verzoek om schadevergoeding tot herstel. De motieven zoals uitgedrukt in de bestreden beslissing hebben de verzoevende partijen dus in staat gesteld om zich meer dan behoorlijk in rechte te verweren tegen deze beslissing. Aldus blijkt het normdoel van de formelemotiveringsplicht zoals deze besloten ligt in de ingeroepen geschonden geachte bepalingen, te dezen te zijn bereikt.

34. In de bestreden beslissing worden de BAFO's als volgt getoetst aan het derde subcriterium 'Fasering van de uitvoering en van de tussenmijlpalen' van het tweede gunningscriterium:

“J.2.3. Fasering van de uitvoering en van de tussentijdse mijlpalen (30 punten)

Wat dit subcriterium voor gunning betreft, onderscheidt de offerte van CFE – BLATON zich vooral wat betreft de verwachtingen van de MIVB. Deze inschrijver toont aan en illustreert dat hij de fasering van de werken in detail bestudeerd heeft en dat hij de noden van de MIVB op het vlak van de beschikbaarheid van het opstelspoor [lees: achterstation] goed

geïntegreerd heeft. Het opstelspoor moet immers zo lang mogelijk exploiteerbaar blijven tijdens het project. De werken in de zone van het opstelspoor (kritiek voor het vrijwaren van de exploitatie) worden immers pas 17 maanden na bevel van aanvang van de werken aangevat. Die benadering wordt gestaafd door een nota die de verbeteringsmaatregelen omvat m.b.t. de beschikbaarheid van de zone (bv. realisatie van een voorlopige helling zonder het gebruik van de bestaande sporen in de zone van het opstelspoor te onderbreken). Bovendien worden er eveneens belangrijke verbeteringen aangebracht op het vlak van het opnieuw openstellen van de Simonetlaan voor het verkeer (7 maanden vroeger dan in de basisplanning). Dat kan bijzonder interessant zijn ten opzichte van de werfcoördinatie -commissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de fasering van de werf dient goed te keuren.

De offerte van FRANKI – JAN DE NUL is toereikend. De voorgestelde fasering is eenvoudig en logisch. De voorgestelde fasering zorgt er in het bijzonder voor dat de werken aan het opstelspoor tamelijk laat aangevat kunnen worden (na 13 maanden), waardoor de onbeschikbaarheid van het opstelspoor tot 4 maanden beperkt wordt. Dat vormt een meerwaarde. Het door deze inschrijver voorgelegde document is echter soms te weinig geïllustreerd. Dat bemoeilijkt het begrijpen van de fasering.

De offerte van BESIX – EJD is eerder ontoereikend wat betreft de verwachtingen van de MIVB. De inschrijver slaagt erin aan te tonen dat hij de door de MIVB gewenste fasering tot op een zeker niveau begrijpt. Toch wordt deze offerte gekenmerkt door een vroegtijdige tussenkomst in de zone van het opstelspoor. Dat brengt een belangrijke storing van het metroverkeer tamelijk vroeg in de loop van de uitvoering (na 8 maanden) met zich mee en heeft een zware impact op de exploitatie van lijnen 1 en 5. De offerte stelt overigens een zeer groot aantal uitrustingen m.b.t. het realiseren van de diepwanden en de baretten voor. In de offerte zijn zo te veel gelijktijdige werkzones voorzien.

Bijgevolg worden de volgende punten toegekend:

Inschrijver	BESIX - EJD	CFE - BLATON	FRANKI - JAN DE NUL
Fasering van de uitvoering en van de tussentijdse mijlpalen op 30 punten	12	27	18

”

35. De verzoekende partijen gaan er in dit middel onterecht van uit dat met het bericht van 18 december 2015 de verwerende partij aangeeft dat de

inschrijvers geen rekening meer moeten houden met de informatie van 15 juni 2015 inzake de zo laat mogelijke aanvang van de werken in het achterstation.

Anders dan de verzoekende partijen veronderstellen, heeft de verwerende partij immers in het bericht met vragen en opmerkingen van 18 december 2015 niet zonder meer meegedeeld dat de werken in het achterstation – welk ook hun tijdstip van uitvoering is – geen invloed meer zouden hebben op de exploitatie van het achterstation. Zij blijkt de inschrijvers te hebben meegedeeld dat, ingevolge de bouw van een eindstation vooraan de halte Erasmus waarvan de afwerking is voorzien tegen eind december 2017, de werken in de zone achter de halte Erasmus vanaf dat tijdstip kunnen worden uitgevoerd zonder risico van interferentie tussen de exploitatie van de metrolijn en de werf. De inschrijvers werden uitgenodigd hun plannings “in voorkomend geval” aan dit gegeven aan te passen. Deze mededeling houdt aldus niet in dat de werken aan het achterstation, op welk tijdstip ook uitgevoerd, geen enkele invloed meer zullen hebben op de exploitatie. Deze mededeling houdt enkel in dat zulks vanaf eind december 2017 het geval zal zijn. Aldus mocht de verwerende partij wel degelijk nog steeds rekening houden met de invloed van de werken in het achterstation op de exploitatie van de metro, in zoverre deze werken door de inschrijver zouden worden ingepland voorafgaand aan de creatie van het eindstation/wisselstation vooraan in de halte Erasmus.

Aldus blijkt niet dat de verwerende partij bij de toetsing van de offertes aan de hand van het subcriterium ‘Fasering van de uitvoering en van de tussentijdse mijlpalen’ zou zijn afgeweken van hetgeen zij aan de inschrijvers heeft meegedeeld in het schrijven met vragen en opmerkingen van 18 december 2015.

Het middel zoals aangevoerd in het verzoekschrift mist aldus feitelijke grondslag.

36. De kritiek gesteund op het verschil in beoordeling tussen de ‘First Offer’ en de BAFO van de verzoekende partijen en betreffende de mijlpaal T1+18m ontwikkelt zij pas in de memorie van wederantwoord en de laatste memorie. Het betreft wel degelijk nieuwe kritiek, waarbij zij eigenlijk of tevens de verwerende partij verwijten dat zij verzoekende partijen niet mogen bestraffen omdat zij in hun BAFO met deze mijlpaal rekening hadden gehouden bij de opmaak van de planning, terwijl de nieuwe informatie na de BAFO tot gevolg had dat de werken in het achterstation door het wegvallen van mijlpaal T1+18 op een later tijdstip, namelijk vanaf eind december 2017, zouden kunnen worden uitgevoerd zonder dat daardoor het bereiken van die mijlpaal, die wegvalt, in het gedrang komt. De Raad van State ziet niet in waarom de verzoekende partijen deze kritiek niet reeds hadden kunnen ontwikkelen in hun verzoekschrift.

De Raad van State ziet, wat de beoordeling ten gronde van deze kritiek betreft, overigens ook niet in waarom de verzoekende partijen niet hadden kunnen antwoorden dat die werken, die zij volgens de bestreden beslissing plannen op 8 maanden na de aanvang van de werken en dus vóór eind december 2017, “effectief” konden worden verschoven naar die latere datum. Zij worden niet “afgestraft” omdat zij in hun BAFO met deze mijlpaal rekening had gehouden bij de opmaak van de planning, maar wel omdat zij niet voldoende of weinig rekening hebben gehouden met de informatie van 15 juni 2015 inzake de zo laat mogelijke aanvang van de werken in het achterstation, waarvan zij nu onterecht beweren dat zij daarmee ingevolge de informatie van 18 december 2015 geen rekening meer zouden mee moeten hebben gehouden.

Voorts is het inherent aan de plaatsingswijze van de onderhandelingsprocedure dat de finale offertes, zoals die aangepast zijn geworden in het proces van de onderhandelingen, in hun onderlinge vergelijking een aanzienlijk hogere of lagere eindscore kunnen behalen dan de provisoire eerste offertes, wat op zich niet dient te leiden tot het vaststellen van een onwettigheid in de beoordeling. Zoals reeds opgemerkt, kwam het aan de verzoekende partijen toe te specificeren hoe zij hun planning effectief zouden

aanpassen in functie van de nieuwe informatie in het bericht van 18 december 2015, zoals zij bevestigden in hun antwoord, en waarbij zij enkel aangaven dat deze aanpassing ook rekening zou houden met het “weglaten van de mijlpaal”. Bovendien kan de mening van de verwerende partij worden bijgevalen dat het logisch is dat de beoordeling van de BAFO’s anders uitviel dan die van de First Offers, nu de voormelde “belangrijke informatie” van 15 juni 2015 inzake de zo laat mogelijke aanvang van de werken in het achterstation werd meegedeeld na de indiening van de First offers en vóór het indienen van de BAFO’s en uitdrukkelijk gevraagd werd daarmee rekening te houden bij de “voorbereiding van de planning”.

37. Het middel wordt verworpen.

D. Vierde middel

Uiteenzetting van het middel

38. De verzoekende partijen voeren in het verzoekschrift de schending aan van artikel 5 *juncto* 55 van de wet overheidsopdrachten 2006, van artikel 106 van het koninklijk besluit plaatsing speciale sectoren, van artikel 4, 8°, *juncto* artikel 5, 9°, van de wet van 17 juni 2013, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van de materiële motiveringsplicht, van artikel 10 en 11 van de Grondwet alsook het algemeen beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie, het zorgvuldigheidsbeginsel, het onpartijdigheidsbeginsel, het transparantiebeginsel en het beginsel *patere legem quam ipse fecisti* als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Zij achten deze bepalingen en beginselen geschonden:

“Doordat verwerende partij de (sub)gunningscriteria zoals aangekondigd in het bestek niet heeft aangehouden als maatstaf voor de beoordeling van de offertes, maar integendeel het subgunningscriterium ‘fasering van de uitvoering en van de tussenmijlpalen’ heeft aangepast in functie van de offerte van de finaal gekozen inschrijver; meer bepaald verviel, op

eenzijdige beslissing van verwerende partij, de in het bestek voorgeschreven vereiste van tussenmijlpaal T1+18 na indiening van de BAFO's;

En doordat het gunningsverslag behept is met fouten en gebreken, inzonderheid doordat op bepaalde punten een manifest foutieve beoordeling is opgenomen voor wat betreft de beoordeling van de offerte van verzoekende partijen, hetgeen een foutieve puntentoekenning tot gevolg heeft;

Terwijl een aanbestedende overheid gehouden is de in het bestek aangekondigde (sub)gunningscriteria als maatstaf te hanteren voor de beoordeling van de offertes;”

In hun toelichting bij het middel wijzen de verzoekende partijen op de eerste plaats op het grote belang in de planning van de “interface” mijlpalen die door de inschrijvers moeten worden nageleefd omwille van de interferentie met andere deelopdrachten van het PULSAR-project. De naleving daarvan is volgens hen van groot belang omdat deze waarborgen dat de uitvoering van andere deelprojecten niet in het gedrang wordt gebracht. Een belangrijke mijlpaal is mijlpaal T1+18 die betrekking heeft op de “terbeschikkingstelling van de eerste 5 opstelposities in de stelplaats, verbindingssporen naar Erasmus station inbegrepen (om de SIG- en 900 V-werken te kunnen beginnen)”.

Dit vereiste verviel echter na indiening van de BAFO's zonder dat de inschrijvers de kans hebben gekregen om hun BAFO's aan te passen. De veronderstelling dat deze interface mijlpalen niet dienden te worden nageleefd, kan niet worden gevolgd. De enkele vaststelling dat een interface mijlpaal moet worden gehaald voordat met een andere deelopdracht van het PULSAR-project kan worden begonnen, doet besluiten dat deze wel degelijk moeten worden nageleefd. Dat het bestek toelaat dat de inschrijvers voorstellen kunnen doen die afwijken van het voorstel van de aanbestedende overheid, leidt niet tot een andere conclusie, aldus de verzoekende partijen. De inschrijvers konden voorstellen doen die de tussenmijlpalen zouden herleiden en daarvoor een hogere score krijgen, maar geen voorstellen die de tussenmijlpalen zouden overschrijden, wat CFE-Blaton te dezen zonder meer heeft voorgesteld. Het subgunningscriterium “fasering van de uitvoering van de tussenmijlpalen” moet de inschrijvers ertoe

aanzetten de planning te herleiden. Voorts bepaalt het bestek dat de inschrijvers voorstellen kunnen doen die afwijken van de voorgestelde planning, doch niet dat de aanbestedende overheid bepaalde mijlpalen zou kunnen loslaten.

Op grond van de beoordeling van de BAFO of offerte na-BAFO van CFE-Blaton in de gunningsbeslissing mag worden besloten dat deze heeft voorgesteld om de werken in het achterstation pas aan te vangen 17 maanden na het aanvangsbevel. Dan kan op geen enkele wijze nog de mijlpaal T1+18 worden gehaald. Het is technisch onrealistisch dat de werken in het achterstation maar één maand zouden duren. In het achterstation moet een toegangshelling worden gebouwd zodat de metrostellen toegang hebben tot de ondergrondse stelplaats. In de planning van de verzoekende partijen en in deze van Franki Construct-Jan De Nul zouden deze werken vier maanden duren. In het gunningsverslag wordt niet gemotiveerd hoe CFE-Blaton hieraan voldoet. De verwerende partij heeft de BAFO of offerte na-BAFO van CFE-Blaton niet zorgvuldig beoordeeld.

Daarenboven heeft de verwerende partij bij de beoordeling van de First Offer van CFE-Blaton vastgesteld dat de planning in een vertraging in de terbeschikkingstelling van de vijf eerste opstelposities voorziet. CFE-Blaton slaagt er met andere woorden niet in tussenmijlpaal T1+18 na te leven, zodat haar 10/30 werd toegekend. Ook in de in de BAFO voorgestelde planning zou CFE-Blaton tussenmijlpaal T1+18 niet halen, maar waar dit in de First Offer werd afgestraft, wordt dit bij de BAFO beloond. Aan de BAFO van CFE-Blaton hadden bijgevolg minder punten moeten worden toegekend. Om te kunnen nagaan of CFE-Blaton op het ogenblik van het indienen van haar BAFO op 18 september 2015 voldeed aan mijlpaal T1+18 en deze niet overschreed, vragen de verzoekende partijen om de vertrouwelijkheid op te heffen van de planning van CFE-Blaton zoals ingediend bij haar BAFO van 18 september 2015. Indien zou komen vast te staan dat tussenmijlpaal T1+18 niet zou worden gehaald, had de verwerende partij de BAFO van CFE-Blaton aanzienlijk minder punten moeten geven. In plaats van dit te doen heeft de verwerende partij het bestek

gewijzigd na de BAFO's, in functie van het afwijkend voorstel van CFE-Blaton. De verwerende partij deelde op 18 december 2015 immers mee dat mijlpaal T1+18 was opgeheven. Dit is een schending van het onpartijdigheidsbeginsel. De verzoekende partijen hebben niet meer de kans gekregen om hun BAFO en hun planning te wijzigen wat een miskennis is van het gelijkheidsbeginsel.

De BAFO's moesten worden beoordeeld met inbegrip van het T1+18 vereiste. Door dit niet te doen is aan het subgunningscriterium "fasering van de uitvoering en van de tussenmijlpalen" een draagwijdte gegeven die niet overeenstemt met hetgeen aangekondigd werd in het bestek. De offertes zijn beoordeeld aan de hand van een gewijzigd bestek waarmee zij geen rekening konden houden bij het opstellen van hun BAFO's. De verwerende partij heeft de offerte van CFE-Blaton gehanteerd als maatstaf om de offerte van de verzoekende partijen te beoordelen.

Dat er sprake is van een partijdige beoordeling is des te frappanter omdat de verwerende partij met een e-mailbericht van 20 januari 2016 CFE-Blaton eraan herinnerde dat de antwoorden op de vragen van 18 december 2015 nog aan de verwerende partij moesten worden bezorgd. CFE-Blaton heeft haar antwoord rechtstreeks aan de leidende ambtenaar bezorgd en niet op het digitale platform sharepoint geplaatst, zoals de procedure bepaalde. De leidend ambtenaar heeft vervolgens pas op 21 januari 2016 de antwoorden op sharepoint geplaatst. Dit is te laat zodat de verwerende partij met het antwoord van CFE-Blaton geen rekening meer mocht houden.

39. In hun memorie van wederantwoord wijzen de verzoekende partijen in de eerste plaats op een arrest van het Hof van Justitie, zaak C-19/00 van 18 oktober 2001, SIAC Constructions ltd, waarin het Hof oordeelde dat de aanbestedende dienst de gunningscriteria tijdens de gehele gunningsprocedure op dezelfde wijze moet uitleggen en dat de gunningscriteria op objectieve en uniforme wijze moeten worden toegepast op alle inschrijvers bij de beoordeling van de aanbiedingen.

De verzoekende partijen wijzen erop dat in het kader van het PULSAR project niet enkel een nieuwe ondergrondse stelplaats moet worden gerealiseerd – het voorwerp van de huidige opdracht – maar ook diverse andere werken moeten worden uitgevoerd. Het is aan de inschrijvers om de opdracht te integreren en te coördineren met de verschillende interfaces die zullen ontstaan als gevolg van de uitvoering van de andere deelprojecten die tot het PULSAR project behoren. De verwerende partij betwist volgens de verzoekende partijen niet dat verschillende interface mijlpalen in het bestek zijn vermeld en de inschrijvers hiermee rekening moesten houden bij de opmaak van hun planning. Indien mijlpaal T1+18 zou worden overschreden, zouden de werken met betrekking tot de opdracht SIG – met betrekking tot de aanleg van de signalisatie in de metro – niet kunnen starten en zou dit deelproject vertraging oplopen. De verzoekende partijen verwijzen naar de schematische weergave van de planning, waaruit volgens hen blijkt dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen kritieke, opgelegde en interface mijlpalen.

Uit het bestek blijkt dat wanneer een inschrijver de termijn van de tussenmijlpalen voorgesteld door de verwerende partij vermindert, in die zin dat deze sneller wordt gehaald dan vooropgesteld, de planning van de inschrijver zal worden beloond. In het subgunningscriterium is geen sprake van enig onderscheid aangaande de draagwijdte van de tussenmijlpalen. De veronderstelling dat de interface mijlpalen niet verplicht dienden te worden nageleefd en dat enkel de kritieke en opgelegde mijlpalen als verplichtend moesten worden beschouwd, kan niet worden gevolgd. Immers, uit het bestek blijkt niet dat de interface mijlpalen louter indicatief zouden zijn; de naleving van de interface mijlpalen is cruciaal voor het PULSAR programma en is opgelegd om de uitvoering van andere deelprojecten niet in het gedrang te brengen; de kritieke, opgelegde en interface mijlpalen hebben dezelfde draagwijdte en moeten door de inschrijvers op gelijke wijze worden gerespecteerd wat blijkt uit de door de verwerende partij voorgestelde planning; in het bestek wordt vermeld dat de inschrijvers voorstellen kunnen doen die afwijken van het voorstel van de aanbestedende overheid, doch dit leidt evenmin tot een andere conclusie en gaat

in tegen de beoordelingsmethodiek die in het bestek is aangekondigd; in bijlage A_ERASME_910_Planning wordt bepaald dat de inschrijvers een geoptimaliseerde offerteplanning moeten indienen die alle mijlpalen van de bijlage A_PULSAR_009 integreert en respecteert, en er wordt geen onderscheid gemaakt in de draagwijdte van de verschillende mijlpalen; het bestek voorziet erin dat indien de interface mijlpalen niet worden gehaald, aanzienlijke vertragingsboetes zullen worden opgelegd; de verwerende partij heeft in haar bericht van 18 december 2015 zelf aangegeven dat mijlpaal T1+18 moet worden beschouwd als een vereiste en dus als een verplicht na te leven mijlpaal.

De verzoekende partijen benadrukken dat de score van hun BAFO van 12/30 tegenover de score van de BAFO van CFE-Blaton van 27 op 30 voor het subgunningscriterium ‘fasering van de uitvoering en van de tussenmijlpalen’ onbegrijpelijk is. De verzoekende partijen hebben een bijna identieke planning ingediend bij de First Offer als bij de BAFO en voor de First Offer kregen zij 30/30. De lage puntentoekenning is het gevolg van het feit dat de verzoekende partijen de werken in het achterstation aanvangen 8 maanden na de start van de werken, terwijl dit bij CFE-Blaton pas 17 maanden na de aanvang van de werken is. Dit zou een interferentie betekenen met de exploitatie van metrolijnen 1 tot 5. De verzoekende partijen hebben verschillende vragen gesteld met betrekking tot de uitvoering van de werken in het achterstation. De verwerende partij heeft op geen enkele wijze aangegeven naar aanleiding van deze vragen dat mijlpaal T1+18 niet langer zou moeten worden gerespecteerd. De werken in het achterstation dienden inderdaad zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor het metroverkeer, maar weliswaar met dien verstande dat op 18 maanden na de aanvang van de werken nog steeds de eerste vijf opstelposities ter beschikking kunnen worden gesteld. De verzoekende partijen hebben hun planning opgesteld in functie van deze twee vereisten van de verwerende partij. Bij de beoordeling van de BAFO van de verzoekende partijen heeft de verwerende partij echter enkel rekening gehouden met de fasering van de werken in het achterstation en niet met de naleving van mijlpaal T1+18. Het is duidelijk dat de verwerende partij de gunningscriteria op een totaal andere wijze heeft

beoordeeld in het kader van de BAFO's dan bij de First Offers. Bij de beoordeling van de BAFO's heeft zij mijlpaal T1+18 laten vallen, terwijl de inschrijvers daar wel rekening mee moesten houden bij de opmaak van hun planning. Dit is een aanzienlijke wijziging van de beoordelingsmethodiek, in strijd met de aangekondigde methodiek.

Met de bewering dat de tussenmijlpaal T1+18 geen bijzonder belang heeft, lijkt de verwerende partij bovendien niet te betwisten dat CFE-Blaton deze mijlpaal in haar BAFO niet respecteert. De verwerende partij verschuilt zich achter het willekeurige onderscheid tussen kritieke, opgelegde en interface mijlpalen.

Het argument van de verwerende partij dat de informatie waarmee de inschrijvers rekening moesten houden bij het opstellen van de BAFO en de First Offer verschillend zou zijn, kan volgens de verzoekende partijen evenmin worden aanvaard. Voor de planning waren er geen relevante verschillen, zo doen zij gelden.

Wat de kritiek op de BAFO van CFE-Blaton betreft, wijzen de verzoekende partijen erop dat de verwerende partij niet aantoont dat de BAFO van CFE-Blaton wel degelijk rekening houdt met mijlpaal T1+18.

De verzoekende partijen benadrukken dat zij in hun BAFO ook alternatieve voorstellen hebben gedaan. Zij hebben naast hun basisoplossing eveneens verschillende andere mogelijkheden onderzocht, weliswaar nog steeds in functie van mijlpaal T1+18. De verwerende partij heeft bij de beoordeling van de BAFO van de verzoekende partijen op geen enkele wijze rekening gehouden met de voorgestelde alternatieven. Evenmin heeft de verwerende partij hierover nog vragen gesteld aan de verzoekende partijen. De verwerende partij heeft integendeel gekozen voor de niet-besteksconforme oplossing van CFE-Blaton en heeft die gebruikt als maatstaf voor de beoordeling van de BAFO's van de andere inschrijvers.

De verwerende partij betwist, zo vervolgen de verzoekende partijen, niet dat zij per e-mailbericht aan CFE-Blaton vroeg om de antwoorden nog te bezorgen. De verwerende partij beroept zich op haar discretionaire bevoegdheid, maar deze laat een aanbestedende overheid niet toe om willekeurig af te wijken van de regels die zij zichzelf heeft opgelegd. Het was de verwerende partij dan ook niet toegestaan met het antwoord van CFE-Blaton van 21 januari 2016 rekening te houden, dit was niet tijdig.

40. In hun laatste memorie blijven de verzoekende partijen erbij dat de in het bestek opgelegde interface mijlpalen wel een verplichtend karakter hebben en hiervan niet mag worden afgeweken. Zij verwijzen naar hun memorie van wederantwoord waar zij uitgebreid en gedetailleerd hebben toegelicht dat alle in het bestek vermelde mijlpalen, zijnde de kritieke, de opgelegde en de interface mijlpalen, dezelfde draagwijdte hebben en voor al deze mijlpalen dezelfde afwijkmogelijkheden gelden, namelijk dat alle mijlpalen kunnen worden herleid of verminderd, maar geen van de mijlpalen kan worden overschreden.

Zij menen dan ook dat de aanstelling van een technisch deskundige weldegelijk noodzakelijk en nuttig is om te kunnen nagaan of de planning van inschrijver CFE - BLATON al dan niet effectief rekening houdt met de naleving van mijlpaal T1+18 en of een termijn van zes maanden effectief voldoende is om de werken in het achterstation te realiseren.

Ten slotte betwisten zij nog, zoals het geval was bij het derde middel, dat hun uiteenzetting over het verschil in puntenbeoordeling tussen de First Offer en de BAFO in de memorie van wederantwoord een bijkomende onontvankelijke kritiek zou zijn.

Beoordeling

41. De verzoekende partijen voeren ook hier de schending aan van de formelemotiveringsplicht zoals die voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en de artikelen 4 en 5 van de wet van 17 juni 2013.

Er kan worden verwezen naar wat hieromtrent reeds werd opgemerkt bij het onderzoek van het derde middel.

Het vierde middel zal hierna worden onderzocht in de mate dat het betrekking heeft op de door de verzoekende partijen aangevoerde grieven over het onderzoek van de offertes bij het subcriterium ‘fasering van de uitvoering en van de tussenmijlpalen’.

42. Het huidige vierde middel is een meer uitgebreide versie van het tweede middel dat de verzoekende partijen hebben doen gelden in de kortgedingprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid, waar het werd verworpen.

De verzoekende partijen herhalen dat ook de tussenmijlpalen noodzakelijk een verplichtend karakter hebben, hetgeen om de volgende redenen echter niet overtuigt.

In het bestek wordt uitdrukkelijk bij de beschrijving van het subcriterium ‘Fasering van de uitvoering en van de tussenmijlpalen’ de mogelijkheid geboden aan de inschrijvers om “voorstellen te doen die afwijken van het voorstel van de aanbestedende overheid”. In de bijlage bij het bestek “III.2. Integratie van het project ‘Stelplaats Erasmus’ in het PULSAR-programma” waarin de mijlpalen worden opgesomd, wordt de door de verzoekende partijen in dit middel ingeroepen tussenmijlpaal T1+18 alleszins niet vermeld onder de categorieën ‘kritieke mijlpalen’ of ‘opgelegde mijlpalen’. Deze mijlpaal T1+18 maakt daarentegen deel uit van de categorie ‘interface mijlpalen’

waarmtrent de betrokken bijlage uitdrukkelijk bepaalt: “De interface[mijlpalen] zullen worden besproken tijdens de gunningsprocedure van deze opdracht”. Hieruit kan dus niet zonder meer worden besloten dat de aanbestedende overheid deze mijlpalen niet zou mogen loslaten of wijzigen.

43. Waar de verzoekende partijen – vooral in hun memorie van wederantwoord uitvoerig – aandringen op het belang van de interface mijlpalen omwille van de afstemming tussen de diverse deelprojecten van het overkoepelend PULSAR-project, komt het in de eerste plaats aan de aanbestedende overheid toe om te waken over de afstemming tussen diverse deelopdrachten van een overkoepelend project en om in te staan voor de coördinatie daarvan. Indien de aanbestedende overheid, zoals te dezen, tot het oordeel komt dat in één deelopdracht een interface mijlpaal mag komen te vervallen, valt dat kennelijk binnen de aan haar toekomstende beoordelingsruimte. Het blijkt alleszins niet dat het bestek de aanbestedende overheid het schrappen van een interface mijlpaal verbiedt, zoals de verzoekende partijen doen gelden. De interface mijlpalen blijken alleszins binnen de marge voor onderhandelingen te vallen, zoals hiervoor en reeds in de procedure kortgeding werd vastgesteld. Het komt in elk geval niet toe aan een inschrijver op één deelopdracht om zijn inschatting inzake de onderlinge afstemming van de diverse deelopdrachten in de plaats te stellen van het oordeel ter zake van de aanbestedende overheid, aan wie de coördinatie van het overkoepelend project toekomt.

44. De verzoekende partijen verwijten in dit middel de verwerende partij eigenlijk geen rekening meer te hebben gehouden bij de beoordeling van de BAFO van de gekozen inschrijver met de naleving van de tussentijdse mijlpaal en dat de gekozen inschrijver de tussenmijlpaal T1+18 in zijn BAFO ook niet zou halen, reden waarom de verwerende partij die ook nadien zou hebben laten vallen.

De verwerende partij verwijst in de beoordeling van de BAFO van de gekozen inschrijver bij het betrokken subcriterium naar diens nota “die de

verbeteringsmaatregelen omvat m.b.t. de beschikbaarheid van de zone (bv. realisatie van een voorlopige helling zonder het gebruik van de bestaande sporen in de zone van het opstelspoor [lees: achterstation] te onderbreken)”. Daaruit blijkt dat de gekozen inschrijver een oplossing voorstelt waarbij een voorlopige helling “zonder gebruik van de bestaande sporen in de zone van het opstelspoor [lees: achterstation] te onderbreken” wordt aangelegd; dit gegeven blijkt uit de als vertrouwelijke neergelegde BAFO van de gekozen inschrijver in het administratief dossier. De betrokken vermelding in de bestreden beslissing heeft betrekking “op de werken in de zone van het opstelspoor (kritiek voor het vrijwaren van de exploitatie)”. In het licht van deze nota van de gekozen inschrijver blijkt aldus deze eigen benadering van de gekozen inschrijver de aanbestedende overheid het meest te hebben aangesproken.

In het kader van de vorige middelen werd reeds gewezen op de belangrijke informatie over de zo lang mogelijke beschikbaarheid van het achterstation van de halte Erasmus. De verwerende partij deelde die informatie mee na de First Offers en vóór de BAFO en vroeg daarin uitdrukkelijk daarmee rekening te houden bij de voorbereiding van de planning die in de BAFO zou worden voorgesteld. In dat licht is het aldus niet onlogisch dat de verwerende partij bij de beoordeling van het betrokken subcriterium daarmee rekening heeft gehouden en dat die beoordeling dan ook anders uitvalt dan die van de First Offers, waar toen niet werd gevraagd met die informatie rekening te houden.

Wat het al dan niet halen van de tussenmijlpaal T1+18 betreft, dient te worden herhaald dat het bestek toelaat dat de interface mijlpalen tijdens de onderhandelingen worden besproken, wat impliceert dat ze aangepast of losgelaten mogen worden.

Bijgevolg is niet voldoende aangetoond dat de verwerende partij bij het verlaten van de interface mijlpaal T1+18 het bestek zou hebben aangepast in functie van de oplossing voorgesteld door de gekozen inschrijver, zoals de verzoekende partijen veronderstellen. Het blijkt dus evenmin dat de

BAFO van de gekozen inschrijver werd gehanteerd als maatstaf om de andere BAFO's aan te toetsen.

De verzoekende partijen tonen ook niet aan en lichten evenmin toe hoe hun alternatieve voorstellen, waarmee de verwerende partij geen rekening zou hebben gehouden, hun vroegtijdige tussenkomst in “de zone van het opstelspoor” of dus het achterstation zouden verhelpen.

45. Voorts blijkt niet welk belang de verzoekende partijen hebben bij de grief gesteund op het feit dat de gekozen inschrijver zijn antwoorden op het schrijven met vragen en opmerkingen van 18 december 2015 per e-mailbericht aan de leidend ambtenaar heeft bezorgd en niet op sharepoint heeft geupload.

Zoals de verwerende partij benadrukt blijkt de gekozen inschrijver zijn antwoorden in elk geval op 20 januari 2016 –dit is tijdig– aan de aanbestedende overheid te hebben bezorgd, zodat hij niet over een eventueel mededingingsverstoring voordeel van extra antwoordtijd heeft beschikt. Alleszins blijkt niet dat de aanbestedende overheid het uploaden van de antwoorden naar sharepoint op straffe van nietigheid of niet-ontvankelijkheid zou hebben opgelegd aan de inschrijvers. Het bestek bepaalt terzake enkel dat de communicatie met de inschrijvers tijdens de onderhandelingen “via elektronische weg” kan verlopen. Voorts kan uit de handelwijze van de gekozen inschrijver die erin bestaat zijn antwoorden per e-mailbericht aan de aanbestedende overheid toe te zenden, niet worden afgeleid dat er sprake zou zijn van een partijdige beoordeling van de offertes in hoofde van de verwerende partij.

46. Waar de verzoekende partijen ook in dit middel grieven doen gelden gesteund op het verschil in de beoordeling van hun First Offer en hun BAFO, kan worden verwezen naar wat daaromtrent hiervoor reeds werd opgemerkt.

47. In de memorie van wederantwoord beroepen de verzoekende partijen zich op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 18 oktober 2001, C-19/00, SIAC Construction Ltd, waarin het Hof overwoog dat de aanbestedende dienst de gunningscriteria gedurende de gehele procedure op dezelfde wijze moet uitleggen. Er wordt te dezen echter niet aangetoond dat de verwerende partij bij de beoordeling van de BAFO's aan het subgunningscriterium 'fasering van de uitvoering en van de tussenmijlpalen' een andere invulling of een andere draagwijdte zou hebben gegeven dan bepaald in het bestek.

Anders dan de verzoekende partijen doen gelden in de memorie van wederantwoord – en daargelaten de vraag of deze kritiek wel tijdig in het debat is gebracht – blijkt niet dat de verwerende partij de beoordelingsmethodiek zou hebben veranderd. De T1+18 interface mijlpaal betreft immers een verandering in de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht, welke voorwaarde zoals vastgesteld in kortgeding *ab initio* binnen de onderhandelingsmarges lag.

48. Het betoog in de memorie van wederantwoord gesteund op de alternatieve uitvoeringswijzen die de verzoekende partijen beweren te hebben voorgesteld in hun offerte en waar de verwerende partij ten onrechte geen rekening zou hebben gehouden, dient als niet ontvankelijk *ratione temporis* te worden verworpen. Dit betoog had immers reeds in het verzoekschrift in het debat kunnen worden gebracht.

49. Het middel wordt verworpen.

E. Vijfde middel

Uiteenzetting van het middel

50. De verzoekende partijen voeren de schending aan van artikel 5 *juncto* artikel 55 van de wet overheidsopdrachten 2006, artikel 106 van het

koninklijk besluit plaatsing speciale sectoren, van artikel 4, 8°, *juncto* artikel 5, 9° van de wet van 17 juni 2013, van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van het gelijkheids-, het zorgvuldigheids- en het materiële motiveringsbeginsel en het *patere legem quam ipse fecisti*-beginsel, en het proportionaliteitsbeginsel.

Zij achten deze bepalingen en beginselen geschonden:

“Doordat, eerste onderdeel, het gunningsverslag behept is met fouten en gebreken, inzonderheid doordat op bepaalde punten een manifest foutieve beoordeling en motivering is opgenomen voor wat betreft de beoordeling van de offerte van verzoekende partijen met betrekking tot het subgunningscriterium ‘uitvoeringsplanning’, hetgeen een foutieve puntentoekenning tot gevolg heeft;

En doordat, tweede onderdeel, het gunningsverslag behept is met fouten en gebreken, inzonderheid doordat op bepaalde punten een manifest foutieve beoordeling en motivering is opgenomen voor wat betreft de beoordeling van de offerte van verzoekende partijen met betrekking tot het subgunningscriterium ‘werfinstallatieplan’, terwijl de vermeende tekortkoming in de offerte van verzoekende partijen die wordt aangehaald in het gunningsverslag geen stand kan houden, hetgeen een foutieve puntentoekenning tot gevolg heeft;

Terwijl, voor de inschrijvers moet vaststaan waarom een bepaalde score wordt toegekend én op welke wijze en op basis van welke motieven de puntenverschillen tussen de inschrijvers tot stand zijn gekomen;

En terwijl, een aanbestedende overheid, zoals verwerende partij, op grond van haar materiële motiveringsplicht ertoe gehouden is om haar beoordeling van de ingediende offertes in het licht van de gunningscriteria en de beoordelingswijze opgenomen in het bestek te steunen op motieven die feitelijk juist en in rechte aanvaardbaar zijn, en dit met de rechte vereiste zorgvuldigheid moet doen.”

De verzoekende partijen lichten toe, wat het eerste middel-onderdeel betreft, dat de beoordeling van hun BAFO-offerte in de gunningsbeslissing aan de hand van het subcriterium ‘uitvoeringsplanning’ onjuist is omdat zij niet in een uitvoeringstermijn voor de funderingswerken van 309 dagen voorzien, maar wel in een uitvoeringstermijn van 220 dagen. Waar de verwerende partij in het kader van de kortgedingprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid heeft beweerd dat er bijkomende voorbereidingswerken moeten

worden bijgeteld om tot 309 dagen te komen, komt het aan de verwerende partij toe om dit aan te tonen.

De verzoekende partijen hebben met 794 kalenderdagen een kortere uitvoeringstermijn voorgesteld dan de gekozen inschrijver met 811 kalenderdagen. Echter werden aan de offerte van de gekozen inschrijver twaalf punten meer toegekend dan aan de offerte van de verzoekende partijen. De motieven daartoe blijken niet uit het gunningsverslag, aldus de verzoekende partijen. Een kloof van 12 punten is niet te verantwoorden nu de voorgestelde planning van de verzoekende partijen “aanzienlijk beter is”. De verwerende partij heeft tijdens de gunningsprocedure te kennen gegeven dat het subgunnings-criterium ‘uitvoeringsplanning’ zou worden onderverdeeld in ‘kwaliteit’ op 20 punten en ‘termijn’ op 20 punten. Nu de verzoekende partijen de kortste uitvoeringstermijn hebben voorgesteld hadden zij hierop 20 punten moeten krijgen. Dit betekent dat zij slechts 4 punten krijgen voor ‘kwaliteit’, het gunningsverslag motiveert niet waarom de verzoekende partijen deze lage score krijgen.

De verzoekende partijen wijzen erop dat hoewel hun uitvoeringsplanning in hun BAFO identiek is aan deze in hun First Offer (wat leidde tot een score van 30/40), het voor hen een raadsel is waarom de verwerende partij oordeelde naar aanleiding van de BAFO dat hun uitvoeringsplanning kwalitatief minder zou zijn. Daarenboven is het onduidelijk welk verband er bestaat tussen de globale uitvoeringstermijn en de uitvoeringstermijn van de funderingswerken. Volgens de verzoekende partijen bestaat er geen dergelijk verband. Daarbij kan worden vastgesteld dat indien de verzoekende partijen effectief 309 dagen nodig zouden hebben voor de funderingswerken en CFE-Blaton 425 dagen, de verzoekende partijen nog steeds 116 dagen meer hebben om de rest van de opdracht af te werken. Ook om die reden is het onduidelijk waarom aan de BAFO van de verzoekende partijen minder punten werden toegekend.

Wat het tweede middelonderdeel betreft inzake de toetsing van hun BAFO-offerte aan het subcriterium ‘werfinstallatieplan’, wijzen de verzoekende partijen erop dat uit geen enkele besteksbepaling blijkt dat zij een gegarandeerde mogelijkheid moesten aantonen om aanpalende sites te gebruiken als werfzone. In elk geval hebben zij in hun offerte wel degelijk aangetoond over de vereiste akkoorden te beschikken en daarnaast hebben zij bijkomende alternatieven voorgesteld. De in het gunningsverslag opgenomen verantwoording is “manifest onjuist” en houdt geen rekening met alle door de verzoekende partijen voorgestelde oplossingen.

Alleszins staat niet vast dat CFE-Blaton wel over een effectief akkoord beschikte met de eigenaars van de sites waarop de werf zou worden geïnstalleerd. Dat CFE-Blaton op 20 januari 2016 een “lettre d’engagement” aan de verwerende partij bezorgde doet niet ter zake volgens de verzoekende partijen, nu CFE-Blaton op datum van de BAFO op 18 september 2015 niet over dit akkoord beschikte. De verzoekende partijen vragen aan de Raad van State om in het administratief dossier na te gaan of deze “lettre d’engagement” mag worden begrepen als een daadwerkelijk akkoord. Alleszins is er een schending van het gelijkheidsbeginsel, nu de verzoekende partijen minder punten hebben gekregen terwijl vaststaat dat CFE-Blaton evenmin over een akkoord beschikte op datum van BAFO.

De verwerende partij verklaart in het gunningsverslag niet waarom bij de First Offer aan de verzoekende partijen een score van 25 punten werd toegekend en bij de BAFO slechts 18 punten. Bijgevolg is er sprake van een schending van de materiële- en formelemotiveringsplicht.

In geen geval kan een vermindering van 12 punten (zijnde slechts 18 in plaats van 30 punten) worden aanvaard omwille van zogenaamde “kleine lacunes”. In het bestek wordt bepaald dat een werfinstallatieplan dat conform is, wordt beloond met 30 punten. Niettegenstaande dat de verwerende

partij vaststelt dat het werfinstallatieplan van de verzoekende partijen besteksconform is, worden 12 punten in mindering gebracht. Dit is disproportioneel.

51. In hun memorie van wederantwoord benadrukken de verzoekende partijen, wat het eerste middelonderdeel betreft, dat de uitvoeringstermijn voor de funderingswerken in hun BAFO 220 dagen bedraagt. De verwerende partij betwist dat niet in haar memorie van antwoord, zij stelt wel dat zij daar nog bijkomende voorbereidingswerken heeft moeten bijtellen. Dat blijkt niet uit het gunningsverslag. De *post factum* motivering in de memorie van antwoord kan niet worden aanvaard. Nergens in de opdrachtdocumenten is er sprake van “voorbereidende werken” die in rekening zouden moeten worden gebracht bij de beoordeling van de uitvoeringstermijn voor de funderingen. Bovendien toont de verwerende partij op geen enkele wijze aan hoe zij tot een termijn van 309 dagen komt. Zij toont dat niet aan de hand van de planning van de verzoekende partijen aan. Daarbij zou de verwerende partij eveneens moeten aantonen dat zij de BAFO van CFE-Blaton op dezelfde wijze heeft beoordeeld en dezelfde voorbereidende werken in acht heeft genomen om de totale uitvoeringstermijn van de funderingen vast te stellen. Dit blijkt evenmin uit het gunningsverslag. Volgens de verzoekende partijen zou, indien in hun planning ook rekening zou worden gehouden met de bouw van de geleidingsmuren, er slechts sprake zijn van een uitvoeringstermijn van 241 kalenderdagen en niet van 309 dagen. De uitvoeringstermijn ligt alleszins aanzienlijk lager dan deze van CFE-Blaton met 425 dagen, zodat het opmerkelijk is dat de verwerende partij aan CFE-Blaton meer punten geeft dan aan de verzoekende partijen.

De verzoekende partijen wijzen erop dat de verwerende partij vertrekt van een foute veronderstelling over het aantal machines dat tegelijkertijd zal worden ingezet. Er zullen enkel op piekmomenten zes machines tegelijk worden ingezet om de funderingswerken uit te voeren, dit werd ook zo door de verzoekende partijen aan de verwerende partij toegelicht in antwoord op een vragenlijst van 7 december 2015. Hieruit bleek dat de verzoekende partijen gemiddeld slechts 5,18 machines zouden gebruiken voor de funderingswerken. In

de foute veronderstelling van de verwerende partij van een uitvoeringstermijn van 309 dagen gaat het om 1.600,62 machinedagen. Voor CFE-Blaton gaat het om 1.700 machinedagen (4 machines en 425 dagen uitvoeringstermijn). Dit is vergelijkbaar. Het besluit van de verwerende partij dat het gebruik van 6 machines geen aanzienlijke verbetering van de globale uitvoeringstermijn tot gevolg heeft en een planningsrisico inhoudt, is onjuist.

De verzoekende partijen wijzen erop dat er tussen hun First Offer en hun BAFO nauwelijks verschillen zijn qua planning. Ook in hun First Offer was er sprake van gemiddeld 5,18 machines voor de funderingswerken. Het blijft voor de verzoekende partijen onduidelijk waarom de verwerende partij bij de BAFO oordeelde dat de planning kwalitatief minder zou zijn. Als zorgvuldige aanbestedende overheid diende de verwerende partij in het gunningsverslag te motiveren waarom de verzoekende partijen aanzienlijk minder punten kregen voor de planning bij hun BAFO dan bij de First Offer. Waar de verwerende partij eerst oordeelde (First Offer) dat de planning kwalitatief was en vervolgens oordeelde (BAFO) dat de planning slechts 4/20 rechtvaardigde, is het gunningsverslag tegenstrijdig. Ook in haar memorie van antwoord verklaart de verwerende partij dit verschil niet.

Wat het tweede middelonderdeel betreft, benadrukken de verzoekende partijen dat er, in tegenstelling tot wat de verwerende partij beweert, geen verplichting was voor de inschrijvers om aan te tonen dat zij een akkoord hadden met de eigenaar van de betrokken aanpalende percelen om deze effectief te gebruiken als werfzone. De verwerende partij miskent de bepalingen van het bestek door te beweren dat de inschrijvers dit toch moesten garanderen. Vervolgens wijzen de verzoekende partijen erop dat zij bij hun BAFO wel degelijk de bevestiging hebben gevoegd dat zij een akkoord hebben gefinaliseerd met de eigenaar van de betrokken site. De verzoekende partijen hebben bevestigd dat zij elk risico op zich zouden nemen indien geen akkoord zou worden bereikt. Op grond daarvan beschikte de verwerende partij dus over de garantie dat de verzoekende partijen over de gronden zouden kunnen beschikken om de werf in

te richten. Een puntenvermindering omwille van het ontbreken van een garantie is dan ook niet verantwoord. De bewering van de verwerende partij in de memorie van antwoord dat het door de verzoekende partijen in hun BAFO voorgestelde alternatief – plan B – niet op dezelfde hoogte zou staan als de oorspronkelijk voorgestelde oplossing is niet correct. Voor de uitvoering van dit akkoord dienden de verzoekende partijen geen nieuw akkoord te verkrijgen, zodat ook dit plan een duidelijke garantie bood. De enkele vermelding dat het een plan B betreft, kan niet leiden tot de vaststelling dat deze oplossing niet als evenwaardig zou moeten worden beschouwd.

Ten slotte doen de verzoekende partijen nog gelden dat de stelling van de verwerende partij dat de formelemotiveringsplicht niet zou inhouden dat moet worden gemotiveerd waarom aan een First Offer meer punten worden toegekend dan aan een BAFO en dat de aanbestedende overheid enkel duidelijk moet maken waarom de inschrijvers een bepaalde score hebben gekregen, geen stand houdt. De verzoekende partijen kunnen op grond van het gunningsverslag niet vaststellen waarom zij maar 18 punten krijgen voor het subgunningscriterium ‘werfinstallatieplan’.

52. In hun laatste memorie stellen de verzoekende partijen, wat het eerste onderdeel betreft, vast dat er discussie bestaat tussen partijen over de duur van de funderingswerken in de uitvoeringsplanning. De verzoekende partijen menen dat er sprake is van 220 dagen. Rekening houdend met de duur van de bijkomende voorbereidende werken die volgens de verwerende partij zou moeten worden bijgeteld, zou er sprake zijn van 241 dagen en volgens het oordeel van de auditeur zouden de funderingswerken bij benadering 309 dagen bedragen. In die zin lijkt de aanstelling van een technische deskundige volgens hen ook op dit punt noodzakelijk en zinvol.

De verzoekende partijen wijzen er voorts nog op dat zij in het verzoekschrift tot nietigverklaring – randnummer 89 – reeds opmerkten dat de verwerende partij het onterecht als negatief beoordeelde dat zes machines zouden

worden ingezet. Hun grief hierover is derhalve wel degelijk tijdig in het debat gebracht en aldus ontvankelijk.

Beoordeling

53. De verzoekende partijen voeren ook in het vijfde middel de schending aan van de formelemotiveringsplicht zoals die voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en de artikelen 4 en 5 van de wet van 17 juni 2013.

Er kan worden verwezen naar wat daaromtrent reeds werd opgemerkt bij het onderzoek van het derde middel.

Het vijfde middel zal hierna worden onderzocht zoals dat betrekking heeft op de door de verzoekende partijen aangevoerde gebreken in het onderzoek van de offertes bij de toetsing van de eerste twee subcriteria van het tweede gunningscriterium.

54. De aanbestedende overheid beschikt bij de inhoudelijke beoordeling van de offertes en hun toetsing aan de gunningscriteria over een grote beoordelingsruimte. De Raad van State is niet bevoegd om de beoordeling van de offertes door de aanbestedende overheid te herdoen of zijn eigen visie daarop in de plaats te stellen van deze van de overheid. De Raad van State kan met de nietigverklaring van de gunningsbeslissing desgevraagd een onwettige, een onzorgvuldige of een buiten de perken van de redelijkheid tredende beoordeling sanctioneren.

Eerste middelonderdeel

55. De motivering van de toetsing van de BAFO's aan het tweede subcriterium 'uitvoeringsplanning' in de bestreden beslissing luidt:

“J.2.2. Uitvoeringsplanning (40 punten)

De offerte van CFE – BLATON voldoet aan de MIVB-vereisten en stelt een uitvoering in 811 dagen voor (datum van voorlopige oplevering van de stelplaats). Uit het dossier blijkt dat het aantal funderingsmachines goed werd bestudeerd om een efficiënte werforganisatie te behouden en de prestaties nodig voor het waarborgen van de uitvoeringstermijn te verzekeren (waaronder 425 dagen funderingswerken met 4 machines).

De offerte van BESIX – EJD leeft de vereisten van de MIVB na met een termijn van 1.095 dagen. Het dossier bevat voldoende details m.b.t. de burgerlijke bouwkunde en er wordt een zeer hoog aantal funderingsmachines voorzien. Toch leidt dat niet tot een duidelijke verbetering van de globale uitvoeringstermijn (waaronder 309 dagen funderingswerken met 6 machines), wat twijfel doet rijzen en een planningsrisico met zich meebrengt.

De offerte van FRANKI – JAN DE NUL respecteert eveneens de vereisten van de MIVB met een aangekondigde termijn van 664 dagen. Volgens de aanbestedende overheid wordt het naleven van de uitvoeringstermijn echter niet gewaarborgd gezien het zeer beperkte aantal machines (328 dagen funderingswerken met slechts 2 machines).”

De verzoekende partijen doen drie grieven gelden tegen die beoordeling van de offertes in de bestreden beslissing, die als volgt kunnen worden samengevat:

- de verzoekende partijen hebben in hun BAFO een uitvoeringstermijn voor de funderingswerken van 220 dagen voorgesteld en geen 309 dagen zoals in de bestreden beslissing wordt gesteld;
- de uitvoeringstermijn van de verzoekende partijen was 794 kalenderdagen, dat is korter dan de 811 kalenderdagen van de gekozen inschrijver, toch krijgen zij 12 punten minder;
- de door de verzoekende partijen voorgestelde uitvoeringsplanning is identiek in hun First Offer en in hun BAFO, toch wordt hun BAFO als kwalitatief minder beoordeeld.

55.1. Wat de grief gesteund op de uitvoeringstermijn van de funderingswerken betreft, wordt het volgende opgemerkt.

Op de eerste plaats dient te worden gesteld dat aan de bestreden beslissing als administratieve rechtshandeling een vermoeden van wettigheid

kleeft. Dat vermoeden is ook verbonden aan het in die beslissing uitgevoerde onderzoek van de offertes. De deskundigheid van een aanbestedende overheid om tot een redelijk en zorgvuldig oordeel te komen bij het onderzoek van de offertes mag bovendien worden vermoed, *a fortiori* wanneer het gaat om een gespecialiseerde overheidsinstantie zoals de MIVB, bijgestaan door evaluatoren, “evaluation leaders”, een Stuurcomité en het Evaluatiecomité PMM.

Het komt aan de verzoekende partijen toe om in het verzoekschrift afdoende aannemelijk te maken dat dit kennelijk minutieus uitgevoerde onderzoek van de offertes toch op onrechtmatige wijze zou zijn verricht of de perken van de redelijkheid zou zijn te buiten gegaan.

De met het onderzoek van de zaak belaste auditeur stelt in zijn verslag vast, na uitvoerig onderzoek van de uitvoeringsplanning en de bijlagen van de BAFO van de verzoekende partijen dat de stelling van de verzoekende partijen dat de funderingswerken in hun geheel slechts 220 dagen in beslag zouden nemen, feitelijke grondslag mist. De auditeur stelt daarentegen vast dat uit de gedetailleerde uitvoeringsplanning van de opdracht in haar geheel van bijlage 8 blijkt dat de funderingswerken in hun totaliteit aanzienlijk langer in beslag zullen nemen:

“Immers blijkt hieruit dat de werken onder lijn ‘ERA310120’ (‘Installation pour Murs emboués + Barettes’, in het Nederlands: ‘Installatie voor diepwanden + baretten’) al op 19 januari 2016 zullen aanvangen, dat is geruime tijd voor de in het verzoekschrift ingeroepen startdatum van 4 maart 2016. Ook blijken de funderingswerken volgens dat totaaloverzicht kennelijk langer te zullen duren dan wordt beweerd in het verzoekschrift, namelijk tot 24 oktober 2016 (zie lijn ‘ERA313645’). Indien daarnaast rekening wordt gehouden met de startdatum van de voorbereidende werken op 18 december 2015, komt men aardig in de buurt van de door de verwerende partij berekende uitvoeringstermijn van de funderingswerken van 309 dagen.”

Ook overweegt de auditeur in zijn verslag dat niet blijkt dat de offerte van de gekozen inschrijver CFE-Blaton niet op dezelfde wijze zou zijn onderzocht:

“Uit nazicht van de bij diens BAFO gevoegde planning blijkt dat, indien de voorbereidende werken en de eigenlijke funderingswerken worden samengeteld, ook bij die inschrijver reeds op het eerste gezicht een uitvoeringstermijn wordt verkregen die de in de bestreden beslissing vastgestelde uitvoeringstermijn van 425 dagen zeer benadert”.

De enkele vaststelling in de laatste memorie dat er dus discussie blijft bestaan tussen partijen over de duur van de funderingswerken in de uitvoeringsplanning van de verzoekende partijen – zelfs als met de verwerende partij rekening wordt gehouden met de bouw van de geleidingsmuren, de voorbereidende graafwerken en de controle op de impetranten), zou er volgens de verzoekende partijen slechts sprake zijn van een termijn van 241 dagen (en geen 309 dagen)– en ook de auditeur enkel “bij benadering” tot die 309 dagen komt, volstaat niet om de voorgaande vaststellingen te weerleggen. De verzoekende partijen maken niet in voldoende mate aannemelijk dat de vaststelling over de duur van de funderingswerken in de bestreden beslissing onjuist zou zijn. Het is aan de verzoekende partijen om concreet aan te geven hoe zij rekening houdend met die opgesomde werken komen tot 241 dagen, terwijl de verwerende partij en de auditeur tot een ander oordeel komen. Zij betwist ook niet uitdrukkelijk de vaststelling in het auditorsverslag over het vroegere begin en het latere einde van de werken “installatie voor diepwanden en baretten”, zodat deze dus meer bedragen dan de beweerde 220 dagen, noch dat de eigenlijke startdatum van de voorbereidende werken, die er nog moeten worden bijgeteld, van die funderingswerken, op 18 december 2015 valt in haar planning.

De kritiek inzake de beweerde foute veronderstelling over de zes machines die tegelijkertijd zullen worden ingezet, en dat enkel op piekmomenten zal worden gewerkt met zes machines, doet niets af aan het voorgaande en zet niet de boordeling in de bestreden beslissing op de helling dat de funderingswerken – met zes machines – van 309 dagen – 116 dagen minder dan die van de gekozen inschrijver - niet leidt tot een duidelijke verbetering van de globale uitvoeringstermijn, die uiteindelijk toch maar 17 dagen korter uitvalt

dan die van de gekozen inschrijver. De verzoekende partijen tonen bijgevolg niet aan de verwerende partij onterecht zou hebben vastgesteld dat er twijfel rijst.

55.2. Wat de grief betreft gesteund op de kortere uitvoeringstermijn van de verzoekende partijen en de lagere puntentoekenning, wordt het volgende opgemerkt.

Bij de adstructie van deze grief blijken de verzoekende partijen het subcriterium ‘uitvoeringsplanning’ te reduceren tot een louter mathematisch criterium in functie van de reductie van de finale uitvoeringstermijn. Overeenkomstig het bestek diende de verwerende partij echter zowel met de kwaliteit van de voorgestelde uitvoeringsplanning als met de voorgestelde inkorting van de finale uitvoeringstermijn rekening te houden bij de beoordeling van de BAFO’s. Het is dus niet noodzakelijk zo dat de kortste uitvoeringstermijn het meeste punten dient te krijgen, zoals de verzoekende partijen eigenlijk doen gelden. In de mate dat deze grief steunt op het loutere feit dat de verzoekende partijen een kortere uitvoeringstermijn hebben aangeboden dan de gekozen inschrijver en daarvoor een hogere score dan die laatste hadden moeten krijgen, mist het middelonderdeel dan ook grond in het bestek.

Voorts kan in dit verband nog worden opgemerkt dat de puntentoekenning voor het subcriterium ‘uitvoeringsplanning’ niet in wanverhouding staat tot de woordelijke motieven, noch tot de uitvoeringstermijnen. Evenmin wordt aannemelijk gemaakt dat de puntentoekenning op willekeur berust.

Ten slotte, wat de grief inzake de in de loop van de onderhandelingsprocedure aan de inschrijvers meegedeelde sub-subgunningscriteria betreft, namelijk kwaliteit en termijn, kan het de verwerende partij niet ten kwade worden geduid dat zij het hanteren van niet in het bestek vooropgestelde sub-subgunningscriteria niet heeft doorgezet bij haar uiteindelijke beoordeling van de BAFO’s van de inschrijvers en uiteindelijk – geheel terecht –

enkel rekening heeft gehouden met het subcriterium zoals uiteengezet in het bestek.

De grief inzake de kortere uitvoeringstermijn en de puntentoeckenning dient te worden verworpen als niet gegrond.

55.3. Wat de grief betreft inzake de verschillende beoordeling van de uitvoeringsplanning bij de First Offer en de BAFO, hoewel de planning daarin identiek was, wordt het volgende opgemerkt.

Herhaald wordt dat het inherent is aan een onderhandelingsprocedure die zoals te dezen door de aanbestedende overheid wordt gestructureerd in fasen met opeenvolgende versies van de offertes, dat de finale offertes, zoals die werden aangepast tijdens het proces van de onderhandelingen, in hun onderlinge vergelijking een aanzienlijk hogere of lagere eindscore kunnen behalen dan de provisoire eerste offertes. Voorts mag worden opgemerkt dat de aanbestedende overheid wanneer zij de offertes toetst aan de hand van de in het bestek bepaalde gunningscriteria, de intrinsieke waarde van een offerte in de onderlinge vergelijking met de andere offertes dient na te gaan.

Het ligt aldus in de logica der dingen dat de uitvoeringsplanning die bij de First Offer een hogere score kreeg en die, zoals de verzoekende partijen zelf doen gelden, ongewijzigd is gebleven tijdens het proces van de onderhandelingen, in de finale beoordeling een andere en lagere inschatting kan verkrijgen dan bij het begin van de onderhandeling. Het feit dat de offerte van de verzoekende partijen onveranderd is gebleven, vormt, geheel anders dan zij veronderstellen, geen garantie op een identieke score.

Bepaalde onderdelen van de werken kunnen bijvoorbeeld ook grondiger worden bestudeerd en daarbij kan worden nagekeken of de voorgestelde uitvoeringstermijnen voor die onderdelen met het voorgestelde materieel wel realistisch is, zoals te dezen is gebleken wat de funderingswerken betreft.

De grief inzake de verschillende beoordeling van de uitvoeringsplanning dient te worden verworpen als niet gegrond.

56. Het eerste middelonderdeel wordt verworpen.

Tweede middelonderdeel

57. Het bestek omschrijft het subgunningscriterium ‘werfinstallatieplan’, het eerste subcriterium van het tweede gunningscriterium als volgt:

“2.10.2. Voorstel uitvoeringsplanning & werfinstallatieplan voor fase 1 – naleving van en inzicht in de fasering van fase 1 (100 punten)

Er wordt aan de inschrijvers gevraagd een gedetailleerd voorstel over te maken voor de hieronder beschreven aspecten (fase 1), in het Algemeen Programma van de Werken (zie bepaling 2.2 en Bijlage L). Realistische voorstellen zullen, na eventuele discussie en uitleg tijdens de onderhandelingen, beloond worden.

(1) Een werfinstallatieplan (30 punten) : Een werfinstallatieplan dat volledig conform is met dit bestek en dat de mobilisatietermijn preciseert, wordt beloond met 30 punten; Voorstellen die niet conform zijn met dit bestek of irrealistisch zijn, zullen bestraft worden, desgevallend tot een nulscore (0 punten).”

58. In de bestreden beslissing wordt inzake de toetsing van de BAFO’s aan het subcriterium ‘werfinstallatieplan’ vermeld:

“J.2.1. Werfinstallatieplan (30 punten)

Wat dit subcriterium voor gunning betreft, voldoen de offertes van de verschillende inschrijvers aan de verwachtingen van de MIVB zoals vermeld in het bestek. De verschillende offertes zijn overtuigend en tonen een beheersing van dit type werven aan. Ze vertonen evenwel ook kleine lacunes (BESIX – EJD: de mogelijkheid om de aangrenzende sites te gebruiken, wordt niet gewaarborgd. CFE – BLATON: het grondverzet en de opslag van grond werden niet grondig genoeg bestudeerd. FRANKI – JAN DE NUL: het verkeer op en naar de site werd niet grondig genoeg bestudeerd).”

De drie offertes krijgen dezelfde score: 18 op 30.

59. In het arrest in de kortgedingprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid nr. 235.683 van 6 september 2016 heeft de Raad van State reeds een bijna identiek middelonderdeel beoordeeld en verworpen.

De auditeur stelt in zijn verslag, met verwijzing naar het voormelde arrest en op grond van de volgende vaststellingen, voor het middelonderdeel als ongegrond af te wijzen:

- het kan niet als onrechtmatig worden aangemerkt dat de verwerende partij in het kader van een subcriterium ‘werfinstallatieplan’ rekening heeft gehouden met de mate waarin de inschrijvers kunnen waarborgen dat zij, indien nodig, ook aan het werfterrein grenzende sites mogen gebruiken voor de werfinstallatie. Dit element ter ondersteuning van de beoordeling van de offertes kan immers zonder meer in de strekking van dat subgunningscriterium worden ingepast.
- uit de BAFO van de verzoekende partijen - meer bepaald de bijlage 1.7.1 ‘Accords avec voisinage’ – blijkt enkel dat zij preliminaire contacten hebben gehad met de eigenaars van de betrokken site, doch geen concrete toelating, zoals de gekozen inschrijver wél bij haar BAFO voorlegt. Enkel blijkt daaruit dat er reeds werd gediscussieerd over de mogelijkheid om een deel van de werf te installeren op een deel van hun terrein.
- De bijkomende alternatieven waarvan de verzoekende partijen in het verzoekschrift gewag maken blijken in hun BAFO in het document 1.7 ‘Plan d’installation de chantier’ door henzelf expliciet als een ‘plan B’ te zijn aangemerkt en worden vervolgens weinig nader geconcretiseerd in de BAFO zelf.
- De gekozen inschrijver kon, anders dan de verzoekende partijen, wel degelijk een concrete en ondertekende verbintenis tot terbeschikkingstelling van een aangrenzend terrein van de nv Erasmus Gardens bij haar BAFO voorleggen.

De verzoekende partijen brengen geen enkele weerlegging van die vaststellingen aan in haar laatste memorie. Zij volharden enkel in het betreffende middelonderdeel en verwijzen naar hun vorige stukken. De Raad van State ziet dan ook in dit licht en op grond van de stukken geen redenen om tot een ander besluit te komen.

Hierbij mag nog worden opgemerkt dat de verbintenis van de gekozen inschrijver slechts in ondergeschikte orde is bijgebracht aangezien hij, zoals reeds opgemerkt bij het eerste middel, met zijn werfinrichting binnen de werfzone zal blijven en in principe geen bijkomende gronden zal nodig hebben.

In de mate dat de verzoekende partijen ook in het tweede middelonderdeel grieven aanvoeren gesteund op het verschil in de beoordeling tussen hun First Offer en hun BAFO, kan worden verwezen naar wat daaromtrent reeds werd uiteengezet bij de beoordeling van het eerste middelonderdeel. Zoals reeds vastgesteld in het kortgedingarrest volstaan de motieven uitgedrukt in de bestreden beslissing wel degelijk om de aan alle inschrijvers voor dit subcriterium toegekende score van 18/30 te dragen.

60. Het tweede middelonderdeel wordt verworpen.

61. Het middel wordt in zijn geheel verworpen.

VII. Deskundig onderzoek

62. In hun memorie van wederantwoord en laatste memorie stellen de verzoekende partijen voor om een deskundige aan te stellen, gelet op “het eerder technisch karakter van in het bijzonder het vierde en het vijfde middel”. Zij geven daarbij de volgende toelichting:

“Een deskundige zou Uw Raad vooreerst kunnen bijstaan bij de beoordeling van het vierde middel en in het bijzonder de vraag of op basis van de planning van CFE - Blaton kan worden vastgesteld dat mijlpaal T1+18 werd gerespecteerd en de werken in het achterstation bijgevolg binnen een termijn van 1 maand zouden worden gerealiseerd. Voor zover Uw Raad evenwel zou oordelen dat de vertrouwelijkheid van de planning van CFE - Blaton inderdaad moet worden opgeheven (zoals verzoekende partijen uitdrukkelijk vragen) kan één en ander mogelijk door Uw Raad ook zelf worden nagegaan. Daarbij kan de deskundige ook beoordelen of verwerende partij gerechtvaardigd was om bij de beoordeling van het subgunningscriterium ‘fasering van de uitvoering en van de tussenmijlpalen’ naar aanleiding van de BAFO slechts 12 op 30 punten toe te

kennen, in vergelijking met de First Offer op basis waarvan 30 op 30 punten werden toegekend.

Daarnaast zou een deskundige Uw Raad kunnen bijstaan bij de beoordeling van de vraag welke termijn verzoekende partijen hebben voorgesteld voor de uitvoering van de funderingswerken (nu verzoekende partijen menen dat zij slechts 220 dagen hebben voorgesteld en verwerende partij meent dat sprake is van 309 dagen), en of de door verzoekende partijen voorgestelde termijn, rekening houdend met het aantal funderingsmachines dat wordt ingezet, realistisch is en bovendien een meerwaarde betekent ten opzichte van de funderingswerken en uitvoeringstermijn die hiervoor door CFE - BLATON is voorgesteld.”

De verzoekende partijen formuleren vervolgens overheen drie bladzijden een concreet voorstel van opdracht voor de aan te stellen deskundige en dragen twee personen voor die als deskundige zouden kunnen optreden.

Beoordeling

63. Het aanstellen van een deskundige is enkel noodzakelijk wanneer in het kader van het onderzoek en de beoordeling van een zaak onoverkomelijke technische vraagstukken rijzen die de Raad van State niet zelf kan beslechten omdat hij niet over de vereiste technische kennis beschikt. Deze technische vraagstukken moeten de Raad van State verhinderen zijn rechtmatigheidsonderzoek te voeren.

Indien de Raad van State over voldoende elementen beschikt om de middelen te beoordelen, dient er niet te worden ingegaan op het verzoek tot het aanstellen van een deskundige.

64. Bij het onderzoek van de vijf middelen is gebleken dat het mogelijk is voor de Raad om de door de verzoekende partijen aangevoerde wettigheidskritieken zelf te onderzoeken en ze te verwerpen. Er is dan ook geen noodzaak om te dezen over te gaan tot het aanstellen van een deskundige.

VIII. Schadevergoeding tot herstel

65. De verzoekende partijen vorderen een schadevergoeding die zij voorlopig begroten op “minstens tien % van het bedrag van de BAFO van verzoekende partijen, t.t.z. tien % van 79.699.101,31 EUR zijnde een bedrag van 7.969.910,13 EUR”. De schade van de verzoekende partijen bestaat erin dat zij de uitvoering van de opdracht hebben mislopen.

Beoordeling

66. Er mag worden aangenomen dat de verzoekende partijen een schadevergoeding tot herstel in de zin van artikel 11*bis* van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bedoelen. Deze vordering tot schadevergoeding tot herstel dient te worden verworpen met toepassing van artikel 25/3, § 3, van het algemeen procedurereglement aangezien er bij de beoordeling van de middelen geen onwettigheid is vastgesteld.

IX. Kosten

67. Het rolrecht voor de vordering tot schadevergoeding tot herstel dient te worden terugbetaald aan de verzoekende partijen als zijnde onverschuldigd, overeenkomstig artikel 70, § 1, vijfde lid, en artikel 72 van het algemeen procedurereglement.

BESLISSING

1. De Raad van State stelt de afstand van de tussenkomst van de nv Aannemingsmaatschappij CFE en de nv CIT Blaton, samen vormend een tijdelijke vennootschap, vast.

2. De Raad van State verwerpt het beroep.

3. De Raad van State verwerpt het verzoek tot schadevergoeding tot herstel.

4. De verzoekende partijen worden verwezen in de kosten van het beroep tot nietigverklaring, begroot op een rolrecht van 400 euro, elk voor de helft en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die verschuldigd is aan de verwerende partij.

Het onverschuldigde recht in verband met het verzoek tot een schadevergoeding tot herstel, begroot op 400 euro, dient aan de verzoekende partijen te worden terugbetaald.

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 19 februari 2019, door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld uit:

Dierk Verbiest,	kamervoorzitter,
Johan Bovin,	staatsraad,
Pierre Barra,	staatsraad,
bijgestaan door	
Silja Doms,	griffier.

De griffier

De voorzitter

Silja Doms

Dierk Verbiest